

故意認定之理論與實務^{*}

— 以殺人與傷害故意之區分難題為核心

徐育安^{**}

目 次

壹、前言	伍、我國實務之綜合觀察模式
貳、故意認定之歷史發展脈絡	一、前提：故意與過失皆係事實
一、實體之取向	二、早期判例意見
二、程序之取向	三、綜合觀察法
參、當代故意理論	四、綜合觀察法之疑義
一、意欲理論之故意認定模式	陸、檢討與建議
二、認識理論之故意認定模式	一、對於學說與實務之反思
肆、德國實務與理論的對話	二、建議（代結論）
一、整體觀察模式之實務運用	
二、法律上的同意與信賴	

* 投稿日：2011年6月20日；接受刊登日：2011年9月7日。〔責任校對：楊承燁、潘佑達。〕

** 德國波昂大學法學博士；東吳大學法學院暨法律學系專任副教授。本文為筆者國科會計畫（計畫編號：98-2410-H-031-035）之部分計畫成果，感謝計畫助理東吳大學法研所研究生陳慶鴻與李慧盈在蒐集資料與附件製表上之協助。本文初稿曾於民國99年10月1日「第五屆學術與實務之對話」研討會發表，會中與談人最高法院林瑞斌法官以及最高法院張淳淙庭長於會後，皆賜與非常寶貴之意見，其後並獲匿名審查人之修改建議，在在對於本文之寫作與修正有重要啟發，於此敬表謝忱，惟文責當仍由筆者自負。

摘 要

我國學說向來致力於故意概念之定義，但實務對此則少有回應，因為在實務上重要的是，故意如何在個案中予以認定，所以關注的是如何證明的問題。無庸置疑的是，刑法學說除了必須發展出一套前後一貫的學理，也需一併思考學說是否具有可行性，否則將淪為紙上談兵。然而，刑法學理迄今已歷經了不同時代的淬煉，當有其理論的基礎與操作上的思考，本文即以此進路檢討故意在實體與程序之間互動關係，並以殺人故意與傷害故意之認定作為討論之核心。

首先，本文探索故意認定在歷史上的發展脈絡，除了鋪陳問題的根源之外，更重要的是，尋找在發展之初，故意的實體與程序上的面貌為何，兩個面向之間是否有某種聯繫。其次，切入的討論主軸是，學說是否提供了一個可以進行實務操作的故意定義，亦即是否學者果真對於故意的證明問題視若無睹，而且可以進一步討論的是，看似實體的故意理論是否在實際上帶有程序性格？對此將區分所謂的認識理論與意欲理論，進行細部之探究。

接著，本文欲探討我國實務之發展現況，除了觀察最高法院在個案判決上的認定方式，如何進行理由上的說明之外。本文更欲藉由大量判決之分析，整理出實務之通案意見，檢討最高法院將故意與過失視為單純事實之見解，將可能衍生的諸多疑義。並且就現行實務所實際使用之綜合觀察模式，審視此一方法所面對的挑戰。最後，本文欲藉由學說與實務之檢討，分析問題的根源後，提出故意認定之具體建議，供作進一步討論與實務之參考。

關鍵詞：故意認定、故意、過失、殺人、傷害、證據。

The Theory and Practice of the Determination of Intent:

On the Distinction Between the Intent to Kill and the Intent to Cause Bodily Harm

*Yu-An Hsu**

Abstract

While the theorists of criminal law have been constantly devoted to the determination of intent, their academic accomplishments seem to have no influence on the practice, where attention has been concentrated on how the existence of intent is to be proved. In order to bridge the gap between theory and practice, this article examines the factor of intent in light of the interaction between substantial and procedural criminal justice. In particular, my analysis is focused on the intent to kill and the intent to cause bodily harm.

First of all, I review and analyze the academic discussions and controversies on the definition as well as determination of intent in historical perspective. Through this analysis, I clarify the relationship between the substantial and the procedural aspects of intent. I then emphasize the significance of these academic discussions for bridging the gap between substantial and procedural meanings of intent and critically examine the practical ignorance of the theoretical foundation for the evidence of intent.

On the basis of the theoretical discussions, I provide a critical analysis of our criminal justice practice. Through a comprehensive and detailed observation on the reasoning of Taiwan Supreme Court, I point

* Doctor of Law, University of Bonn (Germany); Associate Professor of Law, Soochow University School of Law and Department of Law.

out the problems resulting from the Court's viewpoint that both intent and negligence are to be regarded as merely fact. Last but not least, this article endeavors to provide concrete advice as to how the existence of intent should be determined.

KEYWORDS: determination of intent, intent, negligence, homicide, bodily harm, evidence.

壹、前言

不論是我國學界抑或是我們所熟悉的德國刑法學界，對於故意犯之主觀構成要件——故意，向來致力於故意與過失之區辨上，因為故意犯與過失犯之法律效果差異甚大，甚至有許多犯罪並無處罰過失之規定者，是故，這樣的研究傾向是可以理解的，而且對於學術與實務界有一定啟發之功。然而，學界就此議題之研究對於我國審判實務來說，似乎甚少獲得迴響或採納。此一現狀對於學術研究工作者來說，無疑是一個警訊。筆者希望透過本文，對於我國最高法院判決進行一個較為全面性的觀察，完整地討論實務的具體作法，藉此方式可以逐步地描繪出，故意之認定在學說與實務之間的差距。如此，一方面固然是企圖檢討實務的作法是否符合學理上的要求；另一方面，卻也是希望透過這一個過程，檢視學說在實務上的可行性，是否僅為紙上談兵而已。因此，本文盼能以不同的進路檢討故意概念，分析故意之規範性結構，討論此一結構對於故意認定之影響，並進一步檢討故意在實體與程序之間互動關係。這一個互動關係的討論主軸有二：

首先，故意對於實務程序來說，重要的是如何正當化其對於故意之認定，藉由證據適切判斷犯罪故意之有無及其種類。而對於學說而言，則是以把握故意作為一較重之責任型態為核心，對其成立要件予以定義。因此，思考此一問題在實體與程序之間的互動時，可以切入的討論主軸是，學說是否提供了一個可以進行實務操作的故意定義，亦即是否學者果真對於故意的證明問題視若無睹，而且可以進一步討論的是，看似實體的故意理論是否在實際上帶有程序性格？

其次，故意在學理上被切分為認識與意欲要素，似乎將故意概念轉化為兩種心理事實之結合。我國實務先進則認為，對於個案判

決來說，故意與過失是判決書事實欄內所要記載之事實¹，換言之，這是一個事實認定的問題。此一將故意與過失視為單純事實之見解，可能將直接影響第三審之上訴合法性審查，因為，當上訴人對於故意認定提出異議作為上訴理由時，最高法院可能會將此視為「單純事實上之爭執」，因而以程序判決駁回。依此，故意認定問題之屬性，兼其程序與實體之面向，值得進一步討論。

另外，須先敘明的是，由於與故意相關之最高法院判決在數量上不知凡幾，本文乃將探討的範圍侷限在實務如何區分殺人與傷害故意，其理由在於，從一方面來說，殺人與傷害致死兩罪刑度差距不小，所以，此一認定將影響法律效果之幅度頗大，而更有討論價值的原因是，相關案件在實際上的出現頻率頗高，因此，這一部分的討論相信在實務上可說具有相當高之重要性與意義。

貳、故意認定之歷史發展脈絡

某一個行為導致了被害人死亡時，行為人對此應負故意殺人既遂還是故意傷害致死，甚或是過失致死之責，向來被認為是一個主觀歸責上的判定問題。故意與過失之區分固然有其困難，但其中最為棘手的是，傷害故意與殺人故意兩者一線之隔，而人心隔肚皮，應如何予以判定實非易事。對此疑問之思考，可以先回顧我國所師法之德國刑事法制發展，作為探討的起點。德國近代以來對此問題的處理，可以從程序與實體的脈絡探討如下：

1 請參閱48年台上字第1232號、78年台非字第90號判例；我國實務前輩翟宗泉亦指出，故意與過失係「無形之犯罪事實」，見翟宗泉，〈犯罪故意之證明方法〉，《法令月刊》，20卷9期，頁6（1969年9月）。

一、實體之取向

實體上所要處理的是犯罪故意之定義及其要件，而在故意的諸多種類之中，間接故意(*dolus indirectus*)概念在德國的發展歷程，可以說就是一部區分殺人故意與傷害故意之歷史²。緣起可以回溯到17世紀該國刑法學的奠基者 Carpzov (1595-1666)，身集當時刑事實務與學說之大成，他針對殺人故意提出了一個極具有實務價值的問題，亦即對於以高度危險方式攻擊他人者，若其並非以殺人為其目的，但是卻又因該行為之危險性而造成被害人死亡時，是否得以故意殺人論處？由於在當時尚無加重結果犯概念，所以這個問題將影響法律效果甚鉅而具有重要性，Carpzov 對此問題的解決方案是增加犯罪故意的型態。

Carpzov 指出，例如行為人雖僅以傷害他人之意思，但卻持一鋒利長劍刺向被害人身體造成其傷重死亡時，此情形得藉由間接故意之概念肯定故意殺人罪之成立，換言之，其認為故意殺人並不以直接的殺人意志為限，還包括間接的型態。而所謂「間接」的方式，是指在事件的發展過程中，在未有其他外在因素介入的條件下，因行為逕而導致此一死亡結果，這是一種間接而且是透過事件的流程(*indirecte et per accidens*)所確定之意志。依此，間接故意概念的法理基礎在於，藉由行為所具有的客觀特質，亦即行為的高度致命性，從而確認行為人的意志屬性。因此，Carpzov 對此問題的結論是，將殺人故意區分為直接與間接意志兩種類型，而不論是那一種類型，行為人的意志趨向皆是朝著殺害他人邁進(*in actum*

2 間接故意之介紹，已見：許玉秀，〈前行為保證人類型的生存權？——與結果加重犯的比較〉，《主觀與客觀之間》，頁423以下（1997年9月）；柯耀程，〈論加重結果犯〉，林山田教授紀念論文集編輯委員會編，《罪與刑——林山田教授六十歲生日祝壽論文集》，頁139以下（1998年10月）；趙彥清，〈結果加重犯的歸責基礎〉，政治大學法律學研究所碩士論文，頁14以下（1999年）；徐育安，〈間接故意理論之發展——兼論不確定故意、未必故意與附條件故意〉，《東吳法律學報》，21卷3期，頁71-108（2010年1月）。

homicidii)，所以兩者都當以故意殺人罪罰之³。

從間接故意之判斷標準來看，此種故意類型雖然並非純然進行故意的客觀化，因為行為人仍必須具有一傷害之目的，且須認知其所採取的行為手段，例如以長劍刺入他人身體。不過，很明顯的是，間接故意著眼於客觀行為之危險性，採取此一解決方案似乎是因為證據法上的好處，亦即無庸舉證行為人具備殺人犯意。雖然，這的確是一個不可否認的優點，但是，Carpzov 的意見並非基於如此粗糙的理由，他是從行為人身為一個具有生活經驗的理性人出發，指出在這樣的行為情狀之下，不論行為人當下的動機與目的是甚麼，都必然明瞭該其所做所為很可能將造成被害人死亡，所以，我們可以將該結果歸諸於行為人之意志。如此說來，這個論述乃是將主觀歸責繫諸於一個客觀理性人的標準，而非取巧迴避主觀面證明之困難。

間接故意至19世紀初期為德國刑法學泰斗費爾巴哈(Paul Johann Anselm von Feuerbach, 1775-1833)所極力反對，因為，他認為故意之成立，必須是以具有實現犯罪結果之目的為前提，而這一點卻正是間接故意案例所欠缺的，因此主張廢棄此一概念⁴。費爾巴哈指出，在此種案例類型之中，行為人在進行一項故意的犯罪行為時，對於此行為附帶造成的重大結果，事前有所預見或者有預見之可能，這一前一後的兩個部分，前者行為人對於其行為的部分具有故意，而行為人對於後者之結果部分則有過失，因此，費爾巴哈將此種責任型態稱之為透過故意所確立的過失(durch dolus bestimmte culpa; culpa dolo determinate)，成為一種介乎於故意與過失之間的第

3 *Benedict Carpzov*, *Practicae novae imperialis saxonicae rerum criminalium pars I*, übersetzt von Oehler, 2000, Qu. 1. Nr. 28, S. 31 f., 51 f.

4 *Paul J. A. Feuerbach*, *Betrachtungen über dolus und culpa überhaupt und den dolus indirectus insbesondere*, in: v. Almendingen/Feuerbach/Grolman (Hrsg.), *Bibliothek für die peinliche Rechtswissenschaft und Gesetzeskunde*, Bd. 2., 1804, S. 193 (235 ff.).

三種責任型態⁵，亦即今日結果加重犯之前身。

費爾巴哈的解決方案，其後雖然被學說與立法者所接受，但是，在德國的學說與實務上，卻一直到今天都還存在著一個與間接故意頗為近似的故意類型，也就是未必故意(*dolus eventualis*)。此一概念之創始人 Böhmer 對於未必故意的說明，即主要針對殺人故意之判斷提供標準。按照這一個未必故意概念的原型，倘若行為人基於某種侵害目的（如強盜）而對被害人進行一個不被容許之攻擊行為，並已預見到此一行為易於導致被害人死亡，那麼，即便該死亡結果不是他意圖所要達成的，為了原先的目的不受阻礙，行為人無所更改地繼續實行原訂計畫，此即屬對於可能的死亡結果予以同意⁶，從 Böhmer 的說明來看，此與今日所謂的認識理論(*Vorstellungstheorie*)相差無幾，問題僅在於，對於行為人就構成要件實現與否的估算，也就是其預見發生結果可能性之高低程度，在後續的學說上出現概然性說以及危險故意說，要求較高程度之危險性與認識。

二、程序之取向

（一）故意推定之興衰

上述殺人故意概念之演進，其實與故意應如何認定的問題息息相關，間接故意理論的思考，即是將故意視為一個評價性的概念，對於有意採取高度危險性攻擊行為之人，不問其主觀上希望達成何種特殊之目的，亦即不論其目的僅是單純的教訓還是希望置被害人

⁵ Paul J. A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, in: Mittermaier (Hrsg.), 14. Aufl., 1847, Nachdruck 1986, § 60.

⁶ Vgl. Alexander Löffler, Die Schuldformen des Strafrechts in Vergleichend-Historischer und Dogmatischer Darstellung, Bd. I., 1895, S. 172 f.; Friedrich Schaffstein, Die allgemeinen Lehren vom Verbrechen in ihrer Entwicklung durch die Wissenschaft des gemeinen Strafrechts, 1930, Nachdruck 1986, S. 124 f.; Ingeborg Puppe, Der Vorstellungsinhalt des *dolus eventualis*, ZStW 103 (1991), S. 1 (27 Fn. 66).

於死地，乃是藉由該行為的客觀意義為標準據以非難行為人。與之相反，費爾巴哈則是將故意與心理學相連結，使刑法上的故意成為一個如同「憤怒」、「傷心」的心理事實，但是，眾所周知的是，將故意作為待認定之事實，在刑事審判上有其困難，即便能夠取得被告之自白，仍不能謂案情已經就此水落石出，因為，我們無法期待急於自保之刑事被告吐露實情而不避重就輕。更何況要取得此項自白並不容易，甚且常有事後自我推翻者。更進一步來看，若在某一案件中，被害人遭毆打致死，但被告自承僅僅係出於「教訓」被害人之動機而予以傷害，只想「給點顏色瞧瞧」，故主張其當時並無置他人於死地之目的或想法，那麼，審判者應該如何判定本案呢？

基於上述困難與疑問，費爾巴哈曾經主張可以依據行為之客觀特性與經驗法則，在法律上對於故意進行推定(*praesumptio doli*)，此一見解與隨之而出現的實踐，亦即在他所主導的巴伐利亞1813年刑法典中⁷，出現了數個推定故意之規定，完全不令人意外，甚且可說是相當合理的。費爾巴哈曾在其教科書之中對於此一推定賦予理論基礎，他從人類生物性的心理結構（也是一種事實！）出發，作出如下的主張：就任何一個人類的行為來說，有鑒於人類在其精神上的天性，具有意圖必然是最可能的理由，因此，如果以一個任意的行為而造成對外界的作用，但是對該作用卻未懷有目的，那將是一個一般原則之下的特殊例外，而正因如此，若是因為一個任意的行為而導致了一個違法的結果，那麼，也應將其認為係意志的目的

7 巴伐利亞1813年刑法典第四十一條規定：行為人若是為了故意實行一犯罪而進行某一行為，但該行為較易於導致一較為嚴重之犯罪結果，一旦該結果發生時，行為人即對此論以故意之責，而無法主張其目的僅只在於觸犯一較輕之犯罪。其次，在第四十三條中規定：一個針對他人所為之違法行為，法律即可將此行為視為係出於故意而為之，除非有其他特殊情事可以從而得知，該行為必定或可能非出於故意。最後，在第四十四條復又規定，行為人有意地實行一行為，而根據普遍為人所知之經驗，此行為將直接而必然地造成某一結果時，除非另有反證，否則視為行為人意圖該結果之發生。

所致，除非有理由認定係屬例外的情形⁸。

推定對於被告來說，或者將造成舉證責任之倒置，或者將直接予以判定而無法推翻，皆會形成一個不利的地位，因此，費爾巴哈上述推定故意之意見與主張，雖然在發表後也曾獲得部分學者的支持，但是更遭遇到相當嚴厲的反對及批評。反對意見指出，此一推定與羅馬法已降之傳統相悖，且欠缺實質的基礎，因為，推定故意即是在建立一套認定行為人意志之判斷規則，這樣的規則忽略了一個重要的關鍵，亦即人雖能控制其自身的意願，並進而透過行為展現該意志，但是，卻無法決定環境與各種外在條件，尤其是自然界的法則，造成了每一個事件總摻雜著行為人意料之外的偶然因素，因此，我們當無法僅僅透過行為面之觀察與描述，隨即僵化地一律判定有或無犯罪故意⁹。以法律規定推定故意，就是要建立一套普遍適用的判斷模式，確實不得不忽略外在世界的多樣性，極易引發疑慮，是故，故意之推定雖曾引發共鳴，但隨後已被一波波強大的撻伐聲浪所掩過¹⁰。

其後，反對意見顯然收到了成效，費爾巴哈就在他提出此一看法且落實於立法不久之後，卻在其1826年所出版的教科書中徹底的放棄了故意推定的見解，他自己將該見解整段予以刪除，根據其自述，他是相當樂意地撤回之前的看法，而在作此重大意見變更的同時，費爾巴哈將其論述作了如下的轉變，不再以推定的方式原則確定故意之成立，而僅是提供審判者一個在判斷上的參考準則：對於

⁸ *Feuerbach*, (見註5), § 60.

⁹ *Wenig*, Über die Vermutung des bösen Vorsatzes nach dem römischen Rechte, in: *Neues Archiv des Kriminalrechts*, Bd. 2., 1818, S. 194 (197 f.).

¹⁰ 反對者如：*Julius F. H. Abegg*, *Lehrbuch der Strafrechts-Wissenschaft*, 1836, § 88; *Anton Bauer*, *Abhandlungen aus dem Strafrechte und dem Strafprocesse I*, 1840, S. 281; *Augst W. Heffter*, *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts*, 5. Aufl., 1854, S. 62. 正反意見之整理請參閱 *Heinrich Hemmen*, *Über den Begriff, die Arten und den Beweis des Dolus*, 1909, S. 75 ff.

故意與過失之認定，不以透過直接證據之證明為必要，尚可藉由三種間接證據之存在而予以確定，此種證據首先是行為本身所具有之特性；其次為行為與違法結果兩者之間的關聯性；最後，是與行為相關而出現於行為前、行為時及行為後之客觀情狀¹¹。而與此一轉變相互呼應的是，巴伐利亞於1848年修法廢除了上述故意推定之規定，並且也改以與行為相關之諸情狀作為判定之基礎¹²。此一立法之轉折在約莫一世紀後，德國學者 von Hippel 做蓋棺論定時即直率地指出，上述巴伐利亞刑法典中故意推定的規定是完全錯誤的¹³。

費爾巴哈放棄故意推定所帶來的影響，初步看來是正面的，他提供了一個判斷主觀面的客觀連接點，論證哪些事實適合作為判斷基礎，一方面可以避免審判者在推斷上的恣意，在另一方面則是可以正當化審判者的判斷基礎，因此，Grünhut 即指出，這樣的發展說來有些弔詭，原本推定故意的法律擬制規定，卻在其後促成了證據法則上束縛的解脫，成為自由心證的開端¹⁴。而延續此一思考，反對故意推定的學者 Bauer 其清楚地論述道，法官在個案中如遇故意認定上的問題時，應當考量行為時及其前後之所有情狀，以檢視與故意之成立與否有關之徵候(Anzeige)。他並建議應優先檢視下列徵候：1. 被告之人格特質，如年齡、教育程度或名聲；2. 犯罪行為前曾做出之舉動；3. 犯罪之誘因；4. 動機及目的；5. 所使用之犯罪工具；6. 結果之特質與行為間的因果關係，尤其是結果發生之可能

11 Paul J. A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, 9. Aufl., 1826, § 87 Fn. 1; vgl. Max Grünhut, Anselm von Feuerbach und das Problem der strafrechtlichen Zurechnung, 1922, Nachdruck 1978, S. 210.

12 此一變革參考：Robert v. Hippel, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Irrtum, in: Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Allgemeiner Teil, Bd. 3., 1908, S. 454 (458).

13 v. Hippel, (見註12), S. 458.

14 Grünhut, (見註11), S. 211. 相關討論另請參閱徐育安，〈費爾巴哈之故意理論及其影響——以德國刑法為核心〉，《政大法學評論》，109期，頁1以下（2009年6月）。

性高低程度；7. 犯罪後之舉止與態度¹⁵。這一個說明可謂詳細，也可以由此看出自由心證所須考量的因素頗為豐富多樣，此一原始的模型當然會隨著時間的流轉而逐漸演變與應用，耐人尋味。

（二）主觀要件認定之現代建構

在故意之推定被放棄之後，雖然改由法官進行自由心證，但是若未建立一套嚴謹的體系，那麼很可能成為恣意的溫床，可以專擅地臆測行為人想法與態度。因此，必然需要重新思考在程序上如何進行主觀要件之判定，甚至要重新反省故意在法律上的意義。對此問題有啟發性思考的是著名的公法學者 **Kelsen**，他在20世紀初期所出版之「國家法理論的主要問題」一書中，探討私法與刑法中的意志概念(*Willensbegriff*)，他開宗明義地指出，有別於心理學上的意志概念是以人的想法、意念(*Vorstellung*)為對象，而法律上的意志則應是以外在的事件，亦即以法律上的成立要件(*Tatbestand*)為對象。這個說法可能讓人一時無法理解，而其實此話所要傳達的是，因為法學中所要判斷的是某一主體與外在事件之間的關連性，倘若毫無外在事件的存在，在法學上即無運用意志概念之理由與可能，所以，探討法學上的意志概念，即在審視外在事件與行為人之間有何關連¹⁶。

接著，**Kelsen** 就刑法上的故意與過失概念出發，探究刑法上意志概念的特質。他指出明知(*Wissentlichkeit*)之故意類型，僅取決於行為人之認知，並不受到心理上的意欲所影響。而過失更可以說明刑法上意志概念的特殊性，那就在學理上一方面普遍認為罪責以意志為前提，罪責是一種意志責任；另一方面，卻又主張過失與故意不同之處，在於過失欠缺意欲要素。這兩個說法顯然是相互衝突

¹⁵ *Bauer*, (見註10), S. 281 ff.

¹⁶ *Hans Kelsen*, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze*, 1911, S. 121 f.

的，而如此一來，將使過失犯喪失其罪責，這一個結論顯然是荒謬的。就此一矛盾，Kelsen 指出其中的關鍵在於，過失犯其實是一種違反規範之犯罪型態，即便行為人對於犯罪事實並未有所預見，也無情緒上的意欲，仍成立犯罪具備罪責，其罪責是建立在應然之上的，而正因如此，罪責是一個規範性的建構，而非單純由心理上的認知與意欲所構成¹⁷。

藉由上述的說明，Kelsen 提出其具有強烈規範色彩的主張，亦即罪責並非是因為行為人對於某事有所認知與意欲，而是因為他不該如此做且應予以避免¹⁸。這一個說法乍看之下令人難以理解與接受，因為傳統上罪責原則即是以故意與過失為核心，如果知與欲被排除在外，不是就將罪責掏空了嗎。其實 Kelsen 所要指出的是，行為人的主觀認知與感受並非罪責之基礎，規範的違反才是思考罪責的基準點，易言之，罪責來自於規範的違反，這一個看法可以說與規範罪責論是頗為近似的¹⁹。因此，Kelsen 所言僅是強調罪責判斷之根本立足點為何，而非放棄行為人的主觀層面，相反地，他認為許多構成要件中已將行為人的心理過程納入，即已屬不法構成要件之要素，例如特定之意圖(Absicht)，對於此種要素 Kelsen 認為，這與其他構成要件所規定之外在客觀者並無不同²⁰。

進一步言之，雖然立法者將主觀要素列入了不法構成要件之中，但 Kelsen 則是指出，這並不表示我們即因此就藉由探索行為人心理決定如何適用法律，因為這個內心思想的過程是他人包括法律適用者所無法一窺究竟的，只有行為人透過自我的省察才能探悉，那麼，如此一來究竟應該如何決定主觀要素是否具備呢？對於

17 Kelsen, (見註16), S. 133 ff.

18 Kelsen, (見註16), S. 137 f.

19 關於規範罪責理論之介紹，僅參閱 Günther Jakobs, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 1991, 17/7 ff.; Claus Roxin, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, Bd. I., 4. Aufl., 2006, 19/11.

20 Kelsen, (見註16), S. 139.

這個問題他認為，應將此種要素理解為是一種外在的，而且是法律適用者可以在客觀上予以查知的要素，所以，法官即得藉由外在的諸般情狀做出法律上的判定²¹，而這即是在進行所謂的意志的歸責²²。

必須要再特別說明的是，Kelsen 此處所提到的意志是一個從規範的觀點所建構的「法律上的意志」，與一般所謂的心理上的意欲不同，而是一個法律上的建構。此一思考是從最根本的問題出發，亦即法律上所說的主體與生物概念的人(Mensch)並不相同，法律上居於主體地位的，係一法律上具有人格者(Person)，其身負規範上之期待，須履行其義務避免規範之破壞，當為而不為者即受到歸責。Kelsen 指出，刑法上的意志概念即是在這個脈絡之下所建構出來的，而所謂對於犯罪具有「意志」，其實就是指在法律上被歸責之意，與一般我們所言心理上的意欲並不相同²³。

由上述的說明，Kelsen 解決了過失犯也是一種意志責任的矛盾問題，而對於構成要件中的主觀部分，他所提出的客觀判定，對照我們現今就侵占罪之判斷，可以說是確有其理，不但是侵占行為本身，侵占意圖也同樣需透過外在客觀上足以展現此內心目的之行為，方能加以判定²⁴。不過關於故意與過失分界的問題，他的說明確有啟發之效，建立了一個客觀化的理論基礎，有其深遠之影響力²⁵。Hruschka 於1985年針對故意的證明難題，所曾提出的主張，

21 此處 Kelsen 所使用的原文雖然是„juristische Präsumption“，但是，其並非主張可以在法律上可以擬制主觀要件之成立，因此另譯為「法律上的判定」，以免混淆。

22 Kelsen, (見註16), S. 156 f.

23 Kelsen, (見註16), S. 142 ff.

24 Vgl. Wolfgang Ruß, in: LK, 11. Aufl., 1994, § 246 Rn. 13; Urs Kindhäuser, LPK-StGB, 4. Aufl., 2010, § 246 Rn. 12 ff., 31; 許澤天，〈論侵占罪——德國法的啟發〉，《法令月刊》，58卷5期，頁59以下（2007年5月）。

25 較為新近的引證，如：Heinz Koriath, Über den Vorsatz und wie man ihn beweisen könnte, in: Koriath u.a. (Hrsg.), Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie und

雖然未直接引用 Kelsen 之論著，但是其結論可以說是極為相近的，他同樣也認為我們不能再將故意及其要件當作事實來看待，故意並非被確認或是被證明出來的，而是透過歸責而被確立，而他也同樣指出，唯有透過客觀的相關行為情狀始能作為判定此一歸責之基礎²⁶。雖然，Kelsen 與 Hruschka 之主張可謂為一種典範轉移，但是，要如何在實務操作上運用，亦即如何透過客觀事實認定故意，其說明仍過於抽象而模糊。

關於主觀要件之證明問題，德國學說亦頗受到 Engisch 意見之啟發，他在處理與涵攝(Subsumtion)有關之事實認定問題時，針對證據方法(Beweismittel)與間接證據(Indiz)之間的關連指出，在與案情有關之重要事實中，若並非直接透過感官作用查知犯罪者，例如嫌疑人於案發時出現於犯罪現場附近之事實，或某人曾表露犯罪心跡之信函，與此種事實相連結之證據皆屬間接證據，而證據方法則為間接證據之載體以及製造者。間接證據涉及之事實本身是透過感官的方式直接探知的（如前述之嫌疑人出現於某處與信函），法官取得間接證據後透過經驗法則之運用，推論某一待證事實是否真實²⁷。Engisch 此番對於間接證據之探討，成為後來德國學者思考證明主觀要件方式之基礎，這正是由於主觀要件無法在客觀上被他人確實地感知，行為人的認知與情緒的外在呈現可以是不動聲色，也可以做相反的偽裝。因此，主觀要件勢必依賴間接證據，並需要藉助於經驗法則，推論該要件是否具備²⁸。

上述的 Kelsen 與 Engisch 之意見，從兩個不同的角度深化了主

die Reform der Juristenausbildung, 2010, S. 103 (130).

26 Joachim Hruschka, Über Schwierigkeit mit dem Beweis des Vorsatzes, in: Festschrift für Theodor Kleinknecht zum 75. Geburtstag, 1985, S. 191 (200 f.).

27 Karl Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, 3. Aufl., 1963, S. 64 ff.

28 較新近的引證如：Klaus Volk, Begriff und Beweis subjektiver Merkmale, in: 50 Jahre Bundesgerichtshof Festgabe aus der Wissenschaft, 2000, S. 739 (741); Koriath, (見註25), S. 103, 132.

觀要件的證明問題，而德國不論是帝國刑法典或是現行刑法，皆無對於故意概念的直接定義，因此，該國學說與實務對於故意概念之定義，將會與相關證明的思考直接激盪，兩者可以擁有較寬廣的融合空間。以下，即先以當代德國學說出發，探討其區分殺人故意與傷害故意之思考與操作方式，並列入我國學者意見一併予以對照分析。

參、當代故意理論

當代德國區分故意與過失的理論陣營，乃係19世紀認識理論(Vorstellungstheorie)與意欲理論(Willenstheorie)之爭的延續，國內已有專文對此脈絡與發展進行詳細的分析與討論²⁹。而對於本文之目的來說，所欲切入的角度是實體與程序間的交互關係，因此，試圖觀察與分析的問題在於，上述的理論發展與故意之認定，尤其是與殺人故意的認定之間，是以如何的方式聯繫著，是否學說僅是紙上談兵而無法落實在實務的操作上，或者學說為了顧及判斷標準之操作而削足適履，反而忽略了故意之本質。由於意欲理論是較為傳統且為多數學者所支持之見解，當然也正是認識理論的攻擊目標，因此先從此一理論出發討論之。

一、意欲理論之故意認定模式

所謂意欲理論，係指故意之成立要件為，行為人不但於行為時

²⁹ 黃榮堅，〈刑法解題——關於故意及過失〉，《刑法問題與利益思考》，頁13以下（1998年）；黃榮堅，〈故意的定義與定位〉，《刑罰的極限》，頁345以下（2000年）。許玉秀，〈客觀的故意概念？——評德國的間接故意理論〉，《主觀與客觀之間》，頁45以下（1997年9月）；許玉秀，〈區分故意與過失——論認識說〉，《主觀與客觀之間》，頁161以下（1997年9月）；許玉秀，《刑法註釋書研究第12至14條（故意犯與過失犯）》，行政院國家科學委員會專題研究計劃成果報告，計劃編號：NSC-84-2414-H-004-004-013-4，頁35（1997年）。

預見了構成要件將會實現，並且此一結果係該行為人所意欲者³⁰。此一說明，對於德國學說中所謂的第一級直接故意，亦即意圖故意(Absicht)來說並無問題，因為，其意涵正是行為人視特定犯罪為目的。然而，在未必故意之情形中，行為人並不以構成要件之實現為目標，因此，就意欲要件之具備，出現了許多不同學說意見，如同意說、漠然說或認真說等等。在意欲論者中，對於意欲應如何予以認定提出標準者，較為著名的是 Armin Kaufmann，其主張就構成要件之實現言之，予以防免之意志與促其實現之意志兩者，係相互矛盾而無法同時並存，因此，若行為人對於某一結果有所防範時，即可據以排除故意³¹。此一見解，所提供的僅是單一性的指標，在學說上普遍認為有所不足而欠缺說服力³²，也因此 Hillenkamp 提出進一步的改良意見，將防果行為與其他因素相連結，如行為人對於防果措施效果之判斷，行為人是否相信進行防果動作之後，結果將不會發生等一併考量³³。

(一) 故意認定之多元指標

Hassemer 是意欲論者中對於故意之具體認定有特別著墨者，因此，以他作為代表人物予以介紹。首先要說明的是，他對於故意之理解，是從故意較過失處罰為重之思考出發，肯定 Engisch 以來的意欲論立場，同意 Roxin 之主張，認為故意係一侵害法益之「決定(Entscheidung)」，因為，Hassemer 認為，將故意描述為一決定，才能將符合故意被加重處罰的規範邏輯，亦即，行為人具有較過失者高的控制可能性，其參與不法事件之程度較重，故而所受的處罰

30 Vgl. v. Hippel, (見註12), S. 487 f.

31 Armin Kaufmann, Der dolus eventualis im Deliktsaufbau, ZStW 70 (1958), S. 64 (73 ff.).

32 參閱許玉秀，〈客觀的故意概念？——評德國的間接故意理論〉，《主觀與客觀之間》，頁88以下（1997年9月）。

33 Thomas Hillenkamp, Dolus eventualis und Vermeidewille, in: Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 1989, S. 351 (362 ff.).

較嚴厲，這其中意欲的要素的意義是，行為人不但獲悉了法益受到危險之相關資訊，而且接受之作為行為之基礎，這即為對於該危險之「意欲」³⁴。

Hassemer 指出，由於人的內心無法透過觀察而予以描述，同意說、漠然說或認真說等等這些林林總總的故意理論，其實都只是使用其他的日常語言中的詞彙，藉以替換「故意」這一個用語，所以，這僅僅是將刑法上的故意概念加以改寫轉譯(Paraphrasierung)而已，然而，這樣的作法不但無法提供可操作的判斷基準，而且將因日常語言之多變性，而衍生出更多不確定的與殊異的想像空間。而 Hassemer 認為，倘若將故意闡釋為「決定」的話則無上述問題之困擾，而且，「決定」的用語並不會偏重於認識與意欲之間的任何一方³⁵。Hassemer 有別於一般的故意理論之處在於，其特別注重故意概念應如何在程序上予以認定，其理由在於，既然他將故意理解為「決定」，認為故意是一種態度傾向(Disposition)³⁶，而此一態度傾向卻又屬於行為人之內心領域，是他人所無法進入以窺探其究竟者，因此，唯有藉助於外在的一些指標(Indikatoren)，可以間接地證明某種態度之存在，這樣方能推斷行為人是否具有故意。由此，Hassemer 主張，我們不能將故意概念與此概念之指標兩者割裂，這些指標是故意概念在個案上得以適用之前提，兩者不可予以劃分³⁷。這一個立場較為基進，但也可說是學說中較為「務實」者，表面上屬於一種對於純粹實體法理論之反動，其實可以視之為學說與實務所共同醞釀而生的產物，至於他到底提出那些指標，介紹如下。

34 Winfried Hassemer, Kennzeichen des Vorsatzes, in: Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 1989, S. 289 (294 ff.).

35 Hassemer, (見註34), S. 301 f.

36 根據 Hassemer 自己對於 Disposition 一詞之解說，指出故意與意圖等概念乃意謂著人的一種取向、偏好(Neigung)，故本文將此用語譯為「態度傾向」。相關說明見：Winfried Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2. Aufl., 1990, S. 183.

37 Hassemer, (見註34), S. 304 f.; ders., (見註36), S. 184.

Hassemer 首先指出，從故意的處罰理由並非單純著眼於認識要素來看，我們在故意的判斷上不能寄望於單一性的指標，而是要建立一個綜合性的指標清單，這份檢驗的清單所關涉的是認識與決定這兩個內在性的要件，而在檢驗的步驟上，可以區分為下列三個：首先，必須先確認外在的危險，此取決於行為所使用之侵害方式與工具，如炸彈之威力、槍械的使用方式，以及所攻擊之身體部位，上述這些客觀的部分是依賴外在的觀察即可判定。其次，對於認識的部分，行為人是否預見了危險，則透過兩方面的指標予以推斷，一方面是事件的能見度，考慮行為人是否身處現場、與行為客體之距離遠近；另一方面則是行為人的感受能力，考慮有無受到藥物或情緒之影響，行為人個人或專業上的能力。最後，就意欲要素，亦即決定的部分，Hassemer 則是指出，需藉由下列幾個指標予以推斷，有無防果行為、自我侵害之可能性，年少、精神障礙、特殊的職業養成，過去處於類似狀況時之反應，以及行為人與被害人之間的關係如何。

我國學者許玉秀之意見與上述看法有近似之處，主張綜合說是唯一可行並已實踐者，意欲要素應透過各種指標之結合予以判定，亦即綜合所有與風險認知、容忍與接受相關之事實，進行整合性之判斷。此一見解之出發點有二，一方面是從故意將在程序上面對的認定問題著眼，認為實務必將採取綜合說進行審酌。另一方面則是指出意欲要素基於制裁之理性不能放棄，而且意欲之證明並不如認識論者所言那麼困難³⁸，所以仍堅持意欲要素與認識要素一併檢驗。而在審查故意的成立上，容認是一個空洞的公式，需要透過綜合各個學說所提出之要素進行整體的判斷，首先，在認知方面，需要審查的是行為人對於危險的相信（認真）程度；而在意欲方面，若是在控制危險的能力上欠缺確信，亦無防果之意思者，即可肯認

38 許玉秀，〈區分故意與過失——論認識說〉，《主觀與客觀之間》，頁152以下、174（1997年9月）。

意欲要素之存在，而如有證據證明防果意思之存在時，則可排除故意。上述關於意欲要素的兩點，皆為認定意欲之消極要件，而意欲之積極要件為何，則並未另外提出檢驗之標準，而是以認知與意欲的關連性為基礎，主張行為人對於危險的相信程度，將對意欲傳遞動力或予以壓抑³⁹。

（二）類型理論

支持意欲論之德國學者 Schünemann 曾經利用類型學的觀念說明故意的內部構造，並以此建構一套區分殺人與傷害故意的方案。他認為，決定行為支配的認知要素具有層級性，亦即有程度高低之分，對於結果發生機率的認知，從最高的確定有把握一直到最低的不無可能；而侵害法益之敵對意念也同樣會有著強度上的差異性，因此，認識與意欲這兩個要素都可以用程度高低的方式予以分析，兩者所結合而成的故意概念，當然也是具有強度的性質，因此故意的內部結構是具有彈性的，屬於一種類型的思維⁴⁰，乃主張「類型學的故意概念」(typologischer Vorsatzbegriff)⁴¹。

類型的重要特色是，某一個特徵較不明顯的要素可以藉由另一個特徵較明顯的要素而被補強，因此，如果操控能力或是敵視法益的意念是最強烈的形式被表現出來，那麼，其他的要素只要具有最弱的表現，即可在整體上充足成立故意所需之強度，所以，一個出於蓄意的行為，即便結果發生的可能性非常小，和一個出於直接故意的行為，而產生一個絕對非他所期待的附隨結果的情形一樣，都屬於故意。

39 許玉秀，前揭（註38）文，頁156以下。

40 類型學與刑法概念之進一步介紹，請參閱徐育安，《刑法上類推禁止之生與死》，頁61以下（1998年9月）。

41 許迺曼著，許玉秀、鄭昆山譯，〈刑法上故意與罪責之客觀化〉，《政大法學評論》，50期，頁45以下（1994年5月）；許迺曼著，林立譯，〈由語言學到類型學的故意概念〉，許玉秀、陳志輝主編，《不移不惑獻身法與正義——許迺曼教授刑事法論文選輯——賀 許迺曼教授六秩壽辰》，頁459以下（2006年）。

對於行為支配及法敵對意念強度的判斷標準，Schünemann 進一步做如下的補充，他認為可以檢視行為最終目的非價程度、行為人自行承擔風險的心理準備、對被害人所擁有的犯罪支配程度以及社會對於風險的適應，最後，他提出一個分級理論(Staffelungstheorie)，主張在立法者依法益保護的種類或依實害犯和危險犯分列等級之情形，例如殺人與傷害罪，其所屬的兩種故意彼此之間即處於一種強度關係，換言之，前者較後者需要更高之強度方能成立，亦即在知與欲方面的強度是較高的⁴²。

(三) 分析與檢討

依上所述，意欲論的支持者對於意欲要素的認定，傾向以多元的指標進行較為全面的觀察，這似乎是不得不然之舉，因為，意欲要素既然被意欲論者認為是一種情緒性的要素，那麼要掌握這樣隱微的心理變化必須要靠多方的間接證據推斷。而這一個各種指標角力之處，正是混亂與糾結的所在，例如德國聯邦最高法院皮帶案判決(BGHSt 7, 363)⁴³之中，行為人一方面曾試圖以多重的方法避免被害人死亡，可謂已有採取防果措施；但是，在另一方面卻又採取了一個相當危險的方式以拘束被害人之自由，防止其反抗與呼救。依此，在此一案例中，行為人對於被害人可能死亡的態度是自相矛盾的，要如何解開此一糾結正是解決問題的關鍵，然而，意欲論者對

42 許迺曼著，許玉秀、鄭昆山譯，前揭（註41）文，頁49以下、60。

43 本案之事實為：A 與 B 兩人共同計畫對 C 實施強盜行為，原本即打算用皮帶將被害人勒昏，以使其失去抵抗之能力，但卻又擔心 C 因此而死亡，所以決定改用沙袋將其擊昏的方式，使 C 無法抵抗。A 與 B 於行為時先以沙袋用力重擊已經入眠的 C 的頭部兩次，沒想到並未將其擊昏，反而是把他弄醒了，於是兩人又再依此法施為一次，但沙袋卻於此時破裂四散而無法如願將 C 擊昏，兩人只好改回原方案，用所攜的皮帶勒緊被害人頸部與身體，其間 A 為了要完全剝奪 C 的反抗能力而施力猛烈，B 見狀加以制止。而在 A 與 B 兩人搜刮完財物之後，回過頭發現被害人昏迷過久，疑有生命危險而施以人工呼吸，但被害人 C 仍不治死亡。本案之中文參考文獻：許玉秀，前揭（註32）文，頁81以下；林鈺雄，《新刑法總則》，頁182、196（2011年9月）。

此尚欠缺進一步的說明。

認知與意欲要素的連結關係為何，這個問題不但涉及故意的概念結構，也與構成要件錯誤之評價有關，更是意欲論與認識論之間的爭點所在，極富探討之價值。上述意欲論者對於此一問題的意見，彼此之間其實仍有相當的出入。**Hassemer** 對於知與欲的判定是分別獨立的，換言之，依賴兩者各自的指標，互不干涉地予以判定；而許玉秀則是認為，風險的認知程度將會影響意欲之強度，這種作用似乎是單方面的，換言之，意欲對於認知並不具有相同的影響力；至於 **Schünemann** 的類型思考又有不同，主張認識與意欲兩者處於一互補的關係。對於此一問題，意欲論者顯然並未取得共識，而這一點正是認識論者可以見縫插針的機會，以下即從這一點切入介紹認識說對此問題的意見。

二、認識理論之故意認定模式

（一）基本立場

根據意欲論者 **von Hippel** 的看法，認識說的基本出發點在於，其將行為人對於結果之認識作為故意之本質⁴⁴，換言之，意欲要素即非故意之要件。這樣的一個說法即是兩個陣營彼此之間的歧見所在，我們對照支持認識說的學者自己的詮釋，就會發現此一關鍵，主張認識說的代表人物 **Frank** 指出，沒有一位認識論者打算將意欲要素逐出刑法，他們只是認為，意欲要素可以透過行為(*Handlung*)充分地展現出來，因此，無需在定義故意時將意欲納入，而是應當著眼於行為在認定責任上的意義，這也正是在找出認定意欲是否存在的一個審查標準，所以，**Frank** 認為他的立場和意欲論者其實是殊途同歸的⁴⁵。換言之，認識論者主張若行為人對其舉止之後果已

⁴⁴ v. Hippel, (見註12), S. 488.

⁴⁵ Reinhard Frank, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, in: Festschrift für die Juristische Fakultät in Gießen zum Universitätsjubiläum, 1907, S. 521 (541).

有一定之認識，卻仍執意為之者，即可認定行為人意欲導致該結果。

Frank 為認識說所定下的基本立場，其實至今支持本說的學者都不脫這樣的一個基調，只是更加強化其理論基礎而已，而其中最為重要的是 Schmidhäuser 從語言分析為認識說辯護，指出法律上所言之意欲，僅係一種擬制(Fiktion)而已⁴⁶。而 Puppe 及 Kindhäuser 則是從分析行為理論的角度切入證立⁴⁷，Puppe 發展出故意危險(Vorsatzgefahr)理論，其出發點即在於批評德國學說與實務對於意欲要素的檢驗，不但是沒有必要，而且將故意之成立與否繫諸於行為人之恣意決定，以行為人一己之主觀感受為審查基準，忽略了法律判斷在評價上應有的客觀性與立場。按照 Puppe 之故意危險理論，故意之判斷應先依照經驗區分危險之種類，若係一適合於造成結果之危險則稱之為故意危險，反之則係過失危險。如果行為人於行為時認識其所為將造成故意危險，於該危險實現時即須負故意之責，至於行為人在心理上對於結果所抱持之態度為何，是歡迎接受抑或痛苦不捨皆在所不問⁴⁸。

(二) 反對命題之否證法

另一位認識說的重要支持者 Frisch，其對於意欲要素的態度與 Frank 基本上相同⁴⁹，但更進一步以實務上的案例確認，意欲要素在認定故意時是可以被忽略的，其中最重要的是他對於愛滋案判決(BGH 36, 1)之檢討，因此，特別值得在此予以介紹。就愛滋病患者未作安全防護措施即與他人發生性行為之案例，德國聯邦最高法院

46 Eberhard Schmidhäuser, Strafrechtlicher Vorsatzbegriff und Alltagssprachgebrauch, in: Festschrift für Dietrich Oehler zum 70. Geburtstag, 1985, S. 135, (142 f.).

47 Puppe, (見註6), S. 13 f.; Urs Kindhäuser, Vorsatz als Zurechnungskriterium, ZStW 96 (1984), S. 1 (6 ff., 16 ff.).

48 Ingeborg Puppe, in: NK, 2. Aufl., 2005, § 15 Rn. 69; dies., Vorsatz und Zurechnung, 1992, S. 39.

49 Frisch 故意理論之介紹，已見許玉秀，前揭（註32）文，頁67以下。

之意見為，由於該行為製造了性伴侶感染病毒之風險，故應檢驗該國刑法第223條 a 之危險傷害罪(*gefährliche Körperverletzung*)是否該當，而針對犯罪故意之判斷，首先，聯邦最高法院在實體的法律見解上，一方面固然堅持故意需具備認識與意欲兩個要素，並因此認為無法從行為人對於風險之預見即推斷其就此可能發生之結果予以容認，似乎已否定了行為人的認識對於認定有無意欲要素之重要性；但是，在另一方面，於說明應該如何檢驗「容認」時，卻又主張，只要並未超出事實審法院對於諸多具體事實所做的整體評價，那麼，在判斷意欲要素時，還是可以將行為人之認識納入考量⁵⁰。其次，在程序上的證據評價方面，德國聯邦最高法院亦主張，若行為人對於感染風險已有認識，就可以從其認識之性質與強度來推斷得出，關係著意欲要素存在與否之重要的間接證據，就本案來說，按照行為人在性行為方面所具有之經驗知識，對於其所為具有造成感染之風險知之甚詳，這一點可以作為間接證據，證明行為人已有發生危險之心理準備(*Gefährdungsbereitschaft*)。最後，德國聯邦最高法院也同意原判決之看法，以案件調查中行為人所為無意悔過之陳述，以及依據對於其人格特質所為之調查，作為具有意欲要素之表徵⁵¹。

對於上述判決之理由，Frisch 一方面提出批評，認為德國聯邦最高法院針對意欲要素之認定，是語焉不詳而又自失立場的，所以顯然欠缺說服力⁵²。而在另一方面，Frisch 則是對於應如何認定故意提出了積極的建議，當然，這個建議與他認識說的立場是緊密結合的。不過，他首先所提出的，是一個證據法上的檢討，主張刑事

⁵⁰ BGH 36, 1, 11.

⁵¹ BGH 36, 1, 13 f.

⁵² *Wolfgang Frisch*, Gegenwartsprobleme des Vorsatzbegriffs und der Vorsatzfeststellung am Beispiel der AIDS-Diskussion, in: *Gedächtnisschrift für Karlheinz Meyer*, 1990, S. 532 (551 f.); *ders.*, Riskanter Geschlechtsverkehr eines HIV-Infizierten als Straftat? - BGH 36, 11, JuS 1990, S. 362 (367 ff.).

程序上之舉證程序並不是在進行證據之堆疊工作，意即並非藉由累積許多的間接證據以提高待證事實之確定性，依此，他反對 Engisch 以降之傳統意見。與此相反，Frisch 認為舉證程序之進行方式應該是這樣的，為了要確認某一個透過事實得到的假設為真，必須檢驗的其實是，是否可以透過整體事實之審查，排除與上述命題相反之假設，換言之，其主張舉證程序之進程，乃是在於將可能的他種選項予以剔除⁵³。

而就此一 Frisch 所提出的思考運用在故意的問題上，即是指在審查未必故意的問題時，雖然行為人對於危險曾一閃而過的思慮，會將我們導引至行為人具有未必故意的假設；但是，Frisch 指出，此時舉證程序進行的重點並非累積間接證據以認定故意之成立，而是在於行為人就該危險之個人出發點為何，因為，我們需要審視檢驗的是，是否存在著支持相反命題之證據，此處的相反命題即為「行為人成立有認識過失」，而此一命題成立與否的關鍵即在於，行為人是否信賴結果不會發生。接著，為了避免認定有無信賴的問題上可能失諸於籠統，他提出了一些審查的具體標準，如行為人是否曾進行過防果之措施、在統計上危險之程度為何，以及可能在具體情形上因為出於臨時的念頭或一時情緒爆發，所以來不及考慮深思而信賴好運。不過，在最後他認為還是應當將行為人本身的基本態度(*grundsätzliche Haltung und allgemeine Dispositionen des Täters*)納入考慮，生性樂觀的人較易抱持惡果不至於降臨之信賴⁵⁴。

我國亦有採取與認識說相近立場者，學者黃榮堅主張為了兼顧我國第十三條第二項對於意欲要素的要求，以及有效地保護法益，禁絕不尊重他人法益之行為，所以在原則上採取可能性說之標準，

53 Frisch, (見註52), in: *Gedächtnisschrift für Karlheinz Meyer*, 554 ff.

54 Frisch, (見註52), in: *Gedächtnisschrift für Karlheinz Meyer*, 555 ff.; 該文之原文中，並非 *Dispositionen* 而是寫作 *Dispositionen*，經查並無該德文詞彙，故應屬明顯之誤繕或錯印。

藉以擴大故意之範圍，但是，若行為人例外地以保護法益作為其行為之目的時，則可以排除故意之成立。其並認為此一判斷之標準除了更能符合比例原則之外，也滿足了標準的明確性要求，因為判斷行為人之行為目的較防果措施之認定來得容易。而為何較為容易的理由，在於何謂「防果」措施，其認定其實有疑義，例如行為人持槍瞄準被害人的同時，也就可以避免第三人被波及，若可以將此認為是防果措施，則未必故意之成立可能微乎其微；若否，但兩者在外表上卻又無甚區別。最後，黃榮堅認為，若我們從行為人有無保護法益之角度切入，則很明顯的無法認為瞄準之行為屬於一個保護第三人生命的作為⁵⁵。

（三）分析與檢討

若要對於認識說進行分析，還是必須先回到及原本的立場，主張本說之學者認為意欲要素的檢驗無法脫免流於恣意的弊病，因為，法官可能是以直覺判斷行為人的情緒變化，獨斷地認定其看待行為後果之態度。從這一點來看，認識論者試圖透過較為容易從外在事實進行推斷的認知要素，建立一個相對來說較為客觀的審查方式。這樣的思考固然確有其考量，但是，從上述 Frisch 的說明中，我們還是可以清楚地看到，他所主張的故意認定方式同樣會容留一個任意決斷的空間，因為，是否存在著風險不致釀成實害之信賴，他還是從對於行為人的性格出發，審查其個人之處世態度甚至人生觀，如此一來，還是會有任由法律適用者依其直覺判斷的問題。

肆、德國實務與理論的對話

德國聯邦最高法院一如我國最高法院職司法律審，所以其審查

55 黃榮堅，《刑法問題與利益思考》，頁31以下（1995年6月）。

之範圍，侷限於事實審法官之判決有無法律上的瑕疵，而從實質的法律角度言之，如心證是否矛盾、模糊籠統或有漏洞，是否違反論理與經驗法則。而故意此一實體要件是否滿足，當然必須在事實審的階段即予以確定，就此，德國聯邦最高法院將特別審查的是，事實審法官是否在其理由書中確實地檢驗了認知與意欲這兩個故意要素，其認定是否符合論理法則⁵⁶。德國學界將此稱之為一個整體觀察的模式(*Gesamtbetrachtungsmodell*)，因為，為了判斷兩個要素，其所需觀察的面向，包含了行為人與其行為，而非僅審查認知的層面⁵⁷。接著，即針對此一模式運用在殺人故意之特色，作進一步的分析：

一、整體觀察模式之實務運用

(一) 整體觀察模式與梗阻理論之結合

整體觀察模式之實際操作可以做如下的整理：就認識要素來說，事實審法官可從被告對於自身行為之了解推論，他對於結果發生的可能性有所預見，而在進行此一推論時，並且必須同時顧及的是，其是否相信即便有此行為結果仍不至於發生。此一部分在事實審的認定上可說較無困難，尤其是在行為具有發生結果的高度危險性時，因而，在實際案例上，德國聯邦最高法院多所著墨的是，事實審如何認定意欲要素，尤其是如何從行為與行為人對於客觀事實之認識推論意欲要素之具備。

針對殺人故意之認定，德國聯邦最高法院自上個世紀的八〇年代所開始採行的作法，可以區分為下面的兩個步驟。首先，如果被告所進行者屬於對於人身具有重大危險的行為，那麼，德國聯邦最

56 BGH NStZ-RR 2011, 73, 74；較新近之整理見：Georg Steinberg/Fabian Stam, Der Tötungsvorsatz in der Revision des BGH, NStZ 2011, S. 177 (178 f.).

57 Vgl. Torsten Verrel, (Noch kein) Ende der Hemmschwellentheorie?, NStZ 2004, S. 309 (309).

高法院將會同意，行為人原則上應當會對於此種行為所可能造成的死亡結果有所預見，而且可以因此推論其具有意欲。接著，德國聯邦最高法院要求事實審必須檢驗，是否存在著可作相反認定的間接證據(Gegenindiz)，以審查應否推翻在第一個步驟中已為之認定。對此，該院指出，就此種進行高度危險行為的人來說，相較於傷害或是危險故意，在殺人故意之前矗立著一個比較不易跨越的心理障礙(Hemmschwelle)，行為人一般不會在認為被害人將會死亡的情形下，膽敢冒此大不諱，因此，從一方面來說，他或許是由於未預見造成結果之可能，或者是認真而明確地相信結果不至於發生，也就是信賴被害人不至於死亡⁵⁸；從另一方面來說，即便行為人已經對於結果發生之可能性有所認識，也不會輕易地接受死亡這個殘酷的行為後果⁵⁹。而正因如此，在此一步驟之中必須檢驗的是，是否行為人成功地跨越了這道阻礙，這個看法被稱為梗阻理論⁶⁰。

簡單來說，這是一套一正一反的故意認定方式，或者可以說是一個原則－例外(Regel-Ausnahme)⁶¹的思考方式：首先，藉由行為人所從事之高危險行為而推斷其對於後果會有所預見並予以同意，然後審視有無反證足以推翻該同意之認定，亦即可否確定行為人尚未跨越殺人之心理障礙，這一點該如何判斷，可說是關鍵所在，對此，德國聯邦最高法院指出，應審酌的是行為當時所有與犯行相關之主客觀情狀，包含其動機，並且須檢視行為人之性格特質

58 BGH NStZ 1983, 407; NStZ 1988, 361; BGH NStZ-RR 2001, 369.

59 BGH NStZ 2003, 603; BGH: 3 StR 402/04 vom 24.03.2005.

60 總結性的說明，已見於德國聯邦最高法院法官 Lutz Meyer-Goßner 之著作：Lutz Meyer-Goßner, Typische materiell-rechtliche Fehler in Strafurteilen aus revisionsrechtlicher Sicht, NStZ 1986, S. 49 (50)；較新近者請參閱：Christian Fahl, Anmerkung zum Urteil des LG Rostock, Urteil vom 16.09.1996 - I KLS 19/96, NStZ 1997, S. 391 (392); Ulrich Schroth, Der bedingte Tötungsvorsatz im Spiegel der Rechtsprechung, in: Festschrift für Gunter Widmaier zum 70. Geburtstag, 2008, S. 779 (788).

61 Vgl. Verrel, (見註57), S. 310.

(Persönlichkeit)，予以綜合觀察(Gesamtschau)後，據以判斷之⁶²。因此，此一思考模式並非對於實質的故意概念進行改變，而是提出一套關於殺人故意在間接證據上的操作模式⁶³。當然，上述的說法尚欠明確，所以我們需要以具體的例子說明之。

在實際案例的應用上，空手道武者攻擊一案(Karateschlagfall)⁶⁴在文獻上討論較多，行為人是一位訓練有素的空手道武者，其受女友之託照顧剛滿一歲的兒子，某日在該子哭鬧不休時，一怒之下，可能是以出手毆擊其額頭或是抓住後腦杓使其額頭撞擊硬物的方式，造成額部受創。但行為人隨後予以餵食，但是之後卻又是因為此一孩童的哭鬧而再度發怒，因而以手刀至少一次用力攻擊被害人後腦杓與太陽穴之部位，被害人頭部受創於不久後傷重死亡。德國聯邦最高法院對於本案件認為，針對殺人故意的成立有兩點必須被考慮到，首先，因為行為人就死亡結果存有心理障礙，因此無法輕易對於此一結果予以同意。其次，從行為人平時對於被害人的照料來說，可算得上是關心周到，而在案發當日也頗為用心地予以照顧，在兩次攻擊的其間並曾予以餵食，甚至後來還試圖對被害人進行心肺復甦。德國聯邦最高法院基於上述這兩點，認為足以否定殺人故意之成立⁶⁵。我們可以清楚地看到此案中，受到關注的心理現象，一者為無法接受現實「我在殺人、我殺人了」之逃避心態，一者則為基於對行為人的觀察而揣測行為人當時的想法是「教訓小孩」。

62 BGH NStZ 1988, 175; NStZ-RR 2001, 369; BGH NStZ 2003, 603; BGH: 3 StR 402/04 vom 24.03.2005.

63 Steinberg/Stam, (見註56), S. 179 f.

64 BGH NStZ 1988, 175.

65 對此判決予以支持之意見，vgl. Roxin, (見註19), 12/88; ders., Zur Normativierung des dolus eventualis und zur Lehre von der Vorsatzgefahr, in: Festschrift für Hans-Joachim Rudolphi zum 70. Geburtstag, 2004, S. 243 (249). 批評意見：Ingeborg Puppe, Strafrecht, Allgemeiner Teil 1, 2002, S. 302 f.; dies., Begriffskonzeptionen des dolus eventualis, GA 2006, S. 65 (78).

不過，在另一個類似的案件中，德國聯邦最高法院卻有相反的判斷。同樣是一名幫女友照顧兒子的行為人，他雖然對同居女友年約兩歲半的小孩亦多有疼愛呵護，但是對其仍然需要穿尿布這一點則時而感到惱怒，某日行為人再度面臨要幫忙換尿布的麻煩時，火氣一舉爆發，先將被害人打倒在地，再以腳用力踩其腹部並旋轉，造成該名孩童腹部重創肝臟破裂，其後行為人雖試圖進行心肺復甦並送醫急救，終因大量內出血而不治。對於本案，德國聯邦最高法院首先肯定原判決之見解，可以從該行為極強的傷害力，認定行為人對於可能導致的死亡後果有所預見。接著，在意欲要素方面，德國聯邦最高法院也認為原判決並無法律上的瑕疵，因為從行為人在被害人被毆而哀嚎時，仍狠心將踩住腹部的腳予以旋轉來看，可以很容易就推論出其確對於死亡之結果予以接受。至於原判決並未考慮到行為人之後還想和被被害人的母親同住，而且對於行為人試圖對被害人進行心肺復甦的部分，也未予審酌，對此，德國聯邦最高法院卻主張尚不構成瑕疵，其指出，從經驗上來看，確實有可能出現因細故失去控制而對兒童施加暴行，甚且對於死亡結果予以接受之情形，而行為人的事後的追悔或挽救，只是一個相對性的參考點而已，本案例中行為人對於被害人的救護動作，僅是掩人耳目之舉，實際上他所關心的僅止於自己而已⁶⁶。

（二）學界意見之評析

在德國學界除了批評聯邦最高法院之判決標準模糊不清又內容空洞⁶⁷，更有流於恣意之嫌⁶⁸。例如 Puppe 對於空手道攻擊案提出

⁶⁶ BGH NStZ-RR 2001, 369.

⁶⁷ Fahl, (見註60), S. 392; Klaus Geppert, Zur Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit, insbesondere bei Tötungsdelikten, Jura 2001, S. 55 (59); Gerhard Altvater, Rechtsprechung des BGH zu den Tötungsdelikten, NStZ 2002, S. 20 (20 Fn. 10); Hartmut Schneider, MK, § 211 Rn. 24; Verrel, (見註57), S. 310 f.; Thomas Trück, Die Problematik der Rechtsprechung des BGH zum bedingten Tötungsvorsatz, NStZ 2005, S. 233 (238); 部分不同意見：Schroth, (見註60), S. 789.

批評指出，德國聯邦最高法院在其判決中，其實並非就犯罪行為進行判斷，而是著墨於行為人人格如何，觀察其素行及平日為人，同情行為人雖然在過去對被害人善加照料，卻因案發當日的一時之怒而鑄下大錯，而行為人對被害人的攻擊行為，這個判斷的主題因此被忽略了⁶⁹。

上述這些批評適切地指出梗阻理論的問題所在，此標準將犯罪故意的判斷問題，變成了對於行為人人格特質的心理精神分析。值得一提的是，Schünemann 的分級理論解釋了殺人故意與傷害故意之間的關係，一方面似乎可以補強梗阻理論，因為在結論上也贊成殺人故意較不易成立。不過在另一方面，分級理論可以取代梗阻理論，因為依照 Schünemann 的說明，殺人故意必須在知與欲方面具備較高的強度，因此，要成立殺人故意當然較成立傷害故意困難，而非是因為存在著一個心理障礙的緣故。

德國聯邦最高法院對於梗阻理論之適用，似乎頗為依賴其對於行為人之印象與直覺。因為，在判決中已在客觀犯罪事實描述的階段，將其對於行為人人格特質的論斷隱藏其中，以便於其後推導出意欲要素之有無，這在表面上是為判決理由進行論證，但是，在實際上卻是將其主觀之印象，包裝成為客觀之「犯罪事實」，以便掩蓋意欲要素認定上的恣意。誠實地說來，法官難以獲悉行為人進行防果措施之主觀意向，卻要扮演心理醫師的角色進行精神分析，這種法律人所做的性格剖析，其說服力非常薄弱。

二、法律上的同意與信賴

雖然，迄今梗阻理論仍為德國實務界所堅持，但是，這種心理式的故意概念有兩個例外的審查基準，其一是德國實務曾經承認

68 Verrel, (見註57), S. 311.

69 Puppe, (見註65), S. 302 f.

「法律意義上的同意；Billigen im Rechtssinne」概念，其二是德國實務上對於「信賴」之檢驗。首先，就法律意義上的同意來說，具有代表性的是前述皮帶案判決，德國聯邦最高法院認為，實行強盜之行為人既然已經認識其危險的行為方式，可能會造成被害人死亡，那麼，即便行為人此舉之目的是單純謀財而非害命，但是這並不足以否定意欲要素的存在，其理由在於，行為人為了要達成特定目的，如本案中之行為人欲順利實施強盜行為，必要時將忍受一個不希望發生的結果時，德國聯邦最高法院指出，那麼實行強盜之行為人，在法律上來說，即是對此種可能之結果予以接受而同意，換言之，該院主張「同意」固然普遍上是被用來描述行為人之主觀心態，但是除此之外，另有一個從法規範評價觀點出發的同意概念，可稱之為「法律意義上的同意」⁷⁰，不同於單純的心理事實。

此種不同於傳統見解之意欲概念⁷¹，受到德國學界多方攻擊，其癥結還是在於，本案行為人在其主觀的情緒上並不願意見到被害人死亡之結果。如認識說支持者 Schminhäuser 指出，這就是一個清楚的例證，意欲要素應該被放棄，因為，所謂法律上的意欲，只不過是一種虛假的擬制(Fiktion)而已⁷²。而意欲論者如 Roxin，他雖然在結論上也主張本案成立殺人故意，但卻也反對德國聯邦最高法院的作法，認為另外創設出一種意欲概念的話，將會造成專業術語上的錯亂⁷³。而對於該院自己來說，近年來因為梗阻理論之應用大行其道，所以，針對行為人之舉措具有高度危險性之情形，在殺人故意的認定上，已鮮少出現「法律意義上的同意」此一用語。

⁷⁰ BGHSt 7, 363, 369；相同意見，BGHSt 14, 240, 256.

⁷¹ 刑法上意欲概念之發展，參閱 Björn Burkhardt, Der Wille als konstruktives Prinzip der Strafrechtsdogmatik, in: Heckhausen/Gollwitzer/Weinert (Hrsg.), *Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften*, 1987, S. 319 (319 ff.).

⁷² Schminhäuser, (見註46), S. 143.

⁷³ Claus Roxin, Zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit – BGHSt 7, 363, JuS 1964, S. 53 (56).

在德國實務與學說上，對於有認識過失之意義，亦如我國刑法之第十四條第二項之規定，是以行為人預見犯罪構成事實但卻信賴不發生為要件，「信賴」一般在解釋上也是在描述心理事實。依此，此一要件之具備與否，應僅繫諸於該事實能否被證明，換言之，信賴是一個主觀的心理狀態，其存在與否之判斷，就在於我們如何去調查證據證明此一心理事實，這一點與外在事實並無不同，依照這樣的思考，將會得到的結論是，我們只能去證實該事實是否存在，而不能以評價的方式認定，例如，我們不能夠因為買飛機票送人之行為，並不算對於收受者之生命製造法所不容許之風險，從而否定曾有送機票這件事。同樣地，我們也不能因為命令他人上街購物一般來說是安全的，就因此否認有派人採買之事實。

不同於上述所言，德國聯邦最高法院針對故意殺人與過失致死之區分問題，對於被害人因行為人的危險舉措而死亡之案件，在認定有無結果不發生之「信賴」時，卻明確地指出，若是行為人按照所設想之犯罪流程，被害人的生命危在旦夕，而僅能靠老天保佑好運出現時，原則上皆應否定行為人具有死亡結果不發生之信賴⁷⁴。此一看法表面上像是一個事實認定的準則，但其實是認為，行為人之主觀可以藉由一個客觀的標準來判斷，以決定行為人之舉止在法律上的效果，所以，這已經是一個判斷信賴之法律見解，德國聯邦最高法院主張欠缺合理基礎之樂觀想法不足以構成信賴之要件，亦即無法成立刑事責任較輕之有認識過失。

74 BGH NSZ 2005, 92；類似見解，*Kristian Kühl*, *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 5. Aufl., 2005, 5/77.

伍、我國實務之綜合觀察模式

一、前提：故意與過失皆係事實

(一) 判決書之事實與理由

我國實務針對故意問題所表示之相關意見，可溯及至大理院統字第116號解釋：「故意過失之分辨應調查當時之事實」，其指出故意與過失之區辨，需要透過調查行為時之事實作為佐證，這一個看法值得贊同應無疑義，因為所有的法律爭議之解決，都必須先將事實釐清，並將確定之事實涵攝於法律原則或概念之下，以決定其法律效果。但是，本號解釋在現今的實務上其實並未受到重視，甚至出現扭曲，按照本文前言中所提及之最高法院48年台上字第1232號及78年台非字第90號判例，故意與過失應如其他犯罪之相關事實，記載於判決書中之事實欄，這樣的看法與統字第116號解釋有別，因為，本號解釋並未將故意與過失視為事實，而是認為若要區分兩者，非調查行為時之事實不為功。反之，上述兩號判例卻是將故意與過失當作是應被調查的事實的問題，將法律上之評價性概念與事實兩者予以混淆，所以，此一看法可以說是已經明顯脫離統字第116號解釋之原意了。

將故意與過失當作是判決書中事實欄的一部分，乍看之下似乎不成疑問，但其實可以說是差之毫釐失之千里。首先，故意與過失係刑法第十三條與第十四條所明文規定，犯罪成立所必須具備之法律要件，因此，兩者皆屬於法律概念(Rechtsbegriff)，與單純之事實當然有所不同，不可混為一談。舉例言之，某人是否任職於某一政府相關單位及職務為何，固然皆是事實問題，但是，是否此人即為刑法上之公務員，尚必須回到刑法第十條之公務員定義，進行涵攝之後得到結論。因此，將故意與過失視為單純之事實，實有誤會。

必須進一步說明的是，在判決書中事實欄的部分，除了客觀之

犯罪事實以外，當然會涉及行為人主觀方面之事實，例如與犯罪動機相關之情形，而且，也必須要將可能關涉故意與過失之事實釐清，例如行為人是否知悉其行為之危險性，是否出於好意而為，凡此相關之內心事實，當然仍屬事實欄所要記載者。換言之，本欄所要記載的，乃是司法三段論中屬於小前提的部分，亦即「具體事實」，而法律之原則與概念則屬於大前提。依此，事實審法官對於所有進行涵攝時所須檢驗之事實，皆須詳盡調查後確定之。而對於故意與過失問題來說，法官要釐清的事實是，與認識及意欲相關之事實，同時也包括十四條所規定違反注意義務及有無結果不發生確信之事實。所以，在事實欄所必須記載的是，所有與故意及過失之要件相關的事實，以利於判決理由中進行涵攝，但絕非在事實欄處就已經判定故意或過失之成立，而是應該於理由欄中提出認定故意成立與否之論據⁷⁵。

故意與過失往往被當作是一種心理事實，但是，其實德國學界很早就反省到，迄至20世紀初期仍具有重要地位之心理罪責理論，將罪責之基礎訴諸於所謂的心理事實，亦即行為人對於犯罪事實在感官上的心理聯繫，如認知與情緒等等。但是，在無認識過失的情形，行為人於行為時對於結果並無預見也無意欲，所以欠缺一個需要負責之心理事實，這也就是心理罪責論沒落，同時也是規範罪責論興起的原因⁷⁶。這樣說來，無認識過失的行為人，是為了一個不存在的事實而負責，此時要如何進行「事實認定」呢？要解決這個問題必須回到原點，亦即回到無認識過失為何要負責的實體問題，以之作為出發點，來思考那些證據對於成立過失是重要的。同理，我們是否可以單純將故意也認為是靠證據解決的事實認定問題

75 此處可以參閱德國刑事訴訟法上的討論：Hanns Engelhardt, in: Karlsruher Kommentar zur StPO, 6. Aufl., 2008, § 267 Rn. 10; Lutz Meyer-Göbner, StPO, 51. Aufl., 2008, § 267 Rn. 7.

76 此一轉變已於眾多文獻中被提及，如：林山田，《刑法通論（上）》，頁380以下（2008年增訂10版）；Jakobs,（見註19），17/5 Fn. 6; Roxin,（見註19），19/11.

呢？當然不行，因為，如何看待故意作為實體法上的概念，才是故意如何成立之關鍵。故意並不會像是找到兇刀一般被「發現」，而是經過事實之審查後做出的一個規範性判斷，評價行為人具有高度之可非難性。質言之，故意與過失之認定，首先必須檢驗的是認識與意欲這兩個要素，其判斷之妥當性取決於，適當地解讀個案犯罪事實中，藉由經驗法則及論理法則予以推論，這當然屬於判決理由欄中所須說明者。其次，關於錯誤之阻卻故意事由，涉及法律評價之判斷，當然也留待理由欄的部分予以討論。

值得注意的是，於最高法院97年度台上字第2623號判決中，行為人為了攔下被害人車輛與其理論，而對該乘載共計4人之車輛開槍射擊，此一行為是否能成立殺人之故意，最高法院於判決中指出：「行為人對於構成要件雖非積極希望其實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任某個結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之間接故意，此種情形，不得以行為人僅為達到某種目的，據以否定有容任某個結果發生之間接故意存在」。上述理由對於間接故意所提出之說明，提及「法律意義上之容任或接受」之概念⁷⁷，已經證實了部分我國最高法院法官也支持故意屬法律概念。

（二）第三審上訴

我國實務此一對於故意過失屬於事實之看法，對於第三審上訴顯然有重要之影響。例如，在95年度台上字第1774號判決一案中，檢察官於上訴理由中指出，原判決關於被告僅有傷害故意之認定，有違背經驗及論理法則之違背法令，並有理由矛盾之違法。但是，最高法院則是認為，此係原判決所為「合法之事實認定，俱有卷內證據資料足憑，從形式上觀察，原判決並無理由矛盾、證據上適用法則不當或不適用法則等違法之情形存在。按取捨證據及認定事

⁷⁷ 此一說明與德國皮帶案判決所提及之「法律意義上的同意」似有雷同之處，但觀其論述之脈絡，則頗有不同。

實，乃事實審法院職權之行使，其對證據證明力所為之判斷，苟係基於吾人日常生活之經驗，而未違背客觀上應認為確實之定則，並已敘述其何以為此一判斷之理由者，即不能指為違法」，最高法院因此認為，檢察官之上訴理由，乃徒以一己之見漫指原判決為違法，故係欠缺適法之第三審上訴理由，應予程序駁回。

最高法院上述說明，固然在邏輯上具有其一貫性，既然將故意之認定當作事實問題，因此，是以該事實在認定上有無違背相關證據法則，以及有無違反事實認定上之經驗法則，作為審查上訴是否適法之準據。但是，我們可以看到這一個見解的影響相當巨大，因為，上訴理由中其實已經對於原判決在經驗法則、論理法則之推論，以及判決理由的構成上提出甚多具體而確切之質疑，然而，最高法院本於法律審之立場，經常將自己困鎖於本問題係「事實認定」的牢籠之中，而就下級審判決故意認定之疑義，隨即採取「形式上觀察」之方式，可以說是對於此一爭執保持距離，而且針對上訴理由指摘原判決違反經驗法則部分，並未提出確切之說明，即認為上訴不合於法律程式，作成程序駁回判決。

我國最高法院將故意與過失視為單純事實之見解，如我們所見，直接影響了其對於第三審上訴合法性審查之保守態度，容易將當事人之上訴視為「單純事實上之爭執」，因而予以程序駁回。況且，若貫徹此一見解，則影響的層面當然將會是相當廣泛的，涉及故意與過失在全部實務判決中的意義及其審查之方式。以最高法院92年度台上字第5590判決為例，同樣也是對於無殺人故意之上訴予以程序駁回，指出「凡綜合調查所得之各種直接及間接證據，本於推理之作用得其心證，而為事實之判斷，既與事實無違，此項判斷即與完全憑空推測迥異，即不容任意指為違法」，此一說明清楚呈現的問題是，所謂的「與事實無違」並不同於「與經驗及論理法則無違」，後者方為爭執之核心。況且，現行實務普遍的作法是，在判決書中一開始於事實欄中就已道明行為具備犯罪故意，那麼，

以「與事實無違」作為在理由欄中的說明，這也只是結論的重申甚至是循環論證而已。再者，例如在92年度台上字第4617與92年度台上字第5590號判決中，最高法院支持原判決殺人故意之認定，而以駁回上訴，其對於理由之說明，自認僅係一程序性判決，所以僅僅以被告「確有本件犯行」而否定其欠缺殺人故意之上訴理由。

針對此一問題，本文欲指出兩點：首先，從故意概念的演進史來看，故意概念及其成立要件這個看似純粹實體性的問題，其實與故意在審判程序上的判定之間，一直有著密切的關聯性，如果認為兩者涇渭分明，將忽略一個核心的議題，意即在刑法上故意並非是一個單純的心理「事實」，而是作為一個法律概念。因此，故意的判定活動並非是在為某個客觀的事實找出其存在之證據，而是對於一個行為的主觀部分進行規範上的判定，此一認定是否正確，即為判決有無實質理由之根據。因此，對於故意與過失之認定不服，其上訴理由具體指出原判決違反經驗法則或論理法則者，其上訴當然合法及合於法律程式，自當予以實質審理，若捨此不為，即已忽視了第三審之固有功能。

內在事實與外在事實不同之處在於，後者可常與一定之自然法則直接連結；然而，認定內在事實之經驗法則及論理法則為何，則往往是模糊不清或是各自成理的，所以其結論之說服力較易受人質疑。而我國實務上對於殺人故意認定困境的因應之道，早期是藉由與被害人傷勢有關事實，以獲得初步認定之心證，進一步介紹此一判斷方式如下。

二、早期判例意見

（一）殺意及其判斷

我國最高法院早期針對殺人故意之認定問題已曾做成許多判例，首先，18年上字第1309號判例指出：「殺人與傷害人致死之區

別，應以有無殺意為斷，其受傷之多寡，及是否為致命部位，有時雖可藉為認定有無殺意之心證，究不能據為絕對標準」。此處所謂之「殺意」，所指的應是「殺人故意」⁷⁸，最高法院於此判例中主張，被害人之傷勢輕重僅為判斷行為人有無殺意之一種間接證據，但是，如何藉由其他證據強化心證，並未有所說明。

其後，19年上字第718號判例則主張：「殺人與傷害致死之區別，即在下手加害時有無死亡之預見為斷。至受傷處所是否致命部位，及傷痕之多寡，輕重如何，僅足供認定有無殺意之參考，原不能為區別殺人與傷害致人死之絕對標準」，此號判例重申被害人之傷勢輕重僅為判斷之一種間接證據⁷⁹。其後，20年非字第104號判例⁸⁰復又再次申明此一看法。

其後如44年台上字第373號判例指出：「雖殺人與傷害人致死之區別不以兇器及傷痕之多少為絕對標準，然就上述之傷情觀之，則上訴人持刀殺人時下手之重可知，刀能殺人不能謂無預見，下手之重更難謂無殺人之決心。原審並未查有上訴人僅屬意圖傷害之確據，遽認其為傷害人致死，自非允治」⁸¹。值得注意的是，48年台上字第33號判例認為：「上訴人等共同對被害人實施殺害時，如果具有使其喪失生命之故意，其時被害人正在熟睡，而上訴人等各執一刀，致之於死易如反掌，何以上訴人等均僅對其腿部及腳際加害，無一人以刀刺其要害，迨其目的已達自動逸去，並無絲毫反抗，及未有如何障礙，是其用意僅在使腿部殘廢，抑有致之於死之

78 實務上關於這一點應該是確定的，可參閱如最高法院97年度台上字第5888號判決。

79 但令人不解的是，本判例認為殺人與傷害致死之區別在於，行為人在下手加害時是否對於死亡有所預見。此一看法似乎以認識之有無作為唯一之判斷準據，有違民國17年制頒生效之舊刑法第二十六條。

80 「刑法上殺人罪與傷害人致死罪之區別，本視加害人有無殺意為斷，被害人所受之傷害程度，固不能據為認定有無殺意之唯一標準，但加害人之下手情形如何，於審究犯意方面，仍不失為重要參考資料」。

81 其他如最高法院48年度台上字第33號判決亦有類似看法。

決心，已難謂無推求餘地」，以行為人之攻擊部位印證其並無殺害之目的。

觀察上述判例的說明，我們會得到一個初步的印象，即最高法院其實認為，與被害人傷勢相關之事實可以說是殺人故意判斷上的一個起始的出發點，以傷勢為主，而後輔以其他諸般佐證來得到心證上的確信。因此，不令人意外的是，20年上字第1903號判例在被害人未受重大傷害時，作出相反的判斷而認為：「本院前以上訴人與甲婦在警署述詞，僅有商酌用鬧羊花將其毒癲云云，是否確有毒死之故意，抑或僅令麻醉一時以為便利同逃之計，尚待研求，發回更審。茲經更審結果，以甲婦所述當日祇買鬧羊花二仙重量不及一錢，核與調查所得每銅元二枚可購買鬧羊花八分至一錢之事實相符，而中醫公會公函內又稱鬧羊花雖係醉藥之一種，但服食一錢以下不過神經昏亂舉動若狂，原無何等大礙等語。證諸被害人入醫院時不過些少神經錯亂，一經療治，即精神如常，似此以少量之麻醉藥給人服食，尚難謂有殺人故意」。這樣的意見似乎存在著一個法律論理上的漏洞，因為，依此將會造成只要是被害人沒有大礙的情形即否定殺人故意之成立，如此一來，所有的故意殺人未遂恐難成立，而當時尚處罰之不能未遂更難以想像其成立之空間。

（二）殺意與動機之關連性

推敲行為人有無「殺意」，另一個很容易想到的是行為人是否懷有殺人之動機，例如其與被害人之間的恩怨情仇，藉此可以說明行為之背景與原因，正當化故意之認定。就此，最高法院於43年台上字第109號判例中認為：「上訴人因挾被害人怨其家姑與上訴人通姦倒貼之恨，於向被害人索取肥料價款相與口角之際，持長三尺直徑二寸之四方木棍向被害人頭部猛擊三下，致頭蓋骨折倒地，移時斃命，其下手當時，顯已具有殺死之故意，自難解免刑法第二百七十一條第一項之罪責」。本判例中，一開始就提到當事人之間於行

為前就早已存在之恩怨，似乎是以此動機作為思考之出發點。然而，細觀之則可發現，其中認定行為人顯有殺人犯意之關鍵，在於其行為時下手之兇殘，是故，此處仍然是著眼於攻擊行為之危險性，至於與動機相關之部分，判決中所謂「挾被害人怨其家姑與上訴人通姦倒貼之恨」，自其語意言之，似乎僅是在說明行為人動武之藉口，而非一關於犯罪動機之認定。

51年台上字第1291號判例一案中，行為人與被害人先前素不相識，兩人因一時之口角而致鬥毆，依此，行為人似乎並無置被害人於死地之動機，最高法院一方面認為：「殺人與傷害人致死之區別，應以加害人有無殺意為斷，不能因與被害人素不相識，原無宿怨，即認為無殺人之故意」，但是，另一方面卻又主張，但行為人「因事先與被害人爭吵，至相毆打，即不能謂毫無仇怨」，並以行為人「持一木棍尾隨被害人之後，乘其不防，猛擊其頭部，頭部為致命之所，猛擊之使其倒地，已不能謂無死亡之預見，尤其於倒地後，恨猶未消，仍持木棍毆打不停，至令路人睹狀不平，群起呼打，始行遁逃，如非蓄有殺意何以兇悍若此」。就本案之理由而言，不論最高法院對於行為人動機部分之論述是否有說服力，就論述過程言之，同時顧及了主觀動機與客觀傷勢的論述，至少可以說動機是其中一個參考的指標。

另一方面來說，最高法院也指出，畢竟動機與故意不同，而且故意判斷並非以動機之確定為前提，所以，在實務上甚至有認為判決書中可以忽略動機者，如最高法院94年度台上字第2370號判決指出：「通常犯罪之動機，或以之為科刑時應予審酌之事項，或以之為減刑之要件，或以之為加重之要件，惟與犯罪之成立並無必然之關係，事實審雖未查明被告確實之犯罪動機，尚不能指稱有調查職責未盡之違法」，同院99年度台上字第5482號判決，亦同此旨。

三、綜合觀察法

從上述的早期實務意見中，我們可以看到一個還算清楚的輪廓：判斷殺人故意所要審酌的事項皆非絕對，亦即行為人之攻擊方式、力道與被害人傷勢皆只是起始點而已，尚須加上其他的因素合併審酌。而這一個輪廓在近來的判決中，卻日漸模糊，因為，最高法院已將各個參考因素相對化，即便是已對人身重要部位造成嚴重侵害，亦不得欠缺其他因素之檢驗。其典型如83年度台上字第2789號判決指出：「本件上訴人二人均一再否認有殺死陳油清之故意，原判決對上訴人二人之有如何之殺人犯意，亦未詳細說明其認定之理由，僅以『腹部為人體重要器官所在，以水果刀朝腹部猛刺，足以深入腹腔致人於死，被告竟持水果刀朝陳油清之腹部猛刺，傷口長達六公分，且屬深部傷口』云云，專以被害人受傷之部位、輕重為判決基礎，依前開說明，自均有判決理由不備之違法」。因為此一發展，本文乃將我國現今實務作法稱之為「綜合觀察法」，其理由可以從以下的幾個層面予以說明：

（一）綜合觀察法之意義

首先要予以敘明的是，根據最高法院對於主觀要件之基本立場，亦即故意過失係事實之見解，其認為事實審法院對於實體要件一殺人犯意之審查，本即必須綜合調查所得資料，以自由心證予以認定；而最高法院之職權，則是就此一判斷審視有無違反經驗法則或論理法則⁸²，這樣說來，犯罪的主觀要件與客觀要件兩者在審查上並無不同，皆是需要綜合所調查之證據資料後予以判定，特別給予主觀要件之審查一個「綜合觀察法」的名稱，似乎是無意義與必要的。然而，實則我國實務已對主觀要件的審查發展出一套既定的

82 由於為數過多，無法詳盡列舉，例如最高法院79年度台上字第4353號判決、79年度台上字第3880號判決、79年度台上字第3780號判決、83年度台上字第5766號判決、89年度台上字第4171號判決。

說理方式，此方式與德國之整體審查模式有近似之處，進一步說明如下。

或許是由於認定殺人犯意必須由事實審法官在判決的事實部分即先行論述⁸³，因此，綜合觀察法的操作與發展在事實審較為清晰，其中相當具有代表性的是臺灣高等法院臺南分院94年度上訴字第1106號判決，其指出：「行為者於攻擊被害人之際，是否具有殺人之故意，是否有被害人可能因此死亡之預見，及是否違背其本意等情事，均係其內心想法，若非行為人自陳，外人無從窺知，通常僅能由行為者之犯罪動機、原因、受傷處所是否致命部位、傷痕之多寡、輕重如何，及行為者所持之兇器等，形諸於外之客觀行為及行為當時相關情狀，綜合而為認定」。按照此一論述，行為當時之諸般情狀皆須予以考量，稱之以「綜合觀察法」可謂名正言順，但是，其所羅列之各項因素如行為動機、受傷處所、傷痕之多寡輕重、兇器種類，以及客觀行為與行為當時相關情狀，並無先後次序或優劣位之分可言，此與本文前述對於早期實務意見之分析不同。

近來最高法院對綜合觀察法亦再度有清楚之說明，其99年度台上字第2092號判決謂：「殺人未遂與傷害之主要區別端視行為人之主觀犯意，而行為人於加害時，有無殺意或僅具傷害故意，應參酌行為當時所存在之一切客觀環境，如行為人因何原由逞兇，行為當時之手段是否猝然致被害人難以防備，攻擊時之力勁是否猛烈足資使人斃命，及攻擊所用之器具、攻擊部位、次數、用力之強弱、被害人受傷之部位、程度等情況予以審認」。此一說明與臺灣高等法院臺南分院94年度上訴字第1106號判決並無甚差別，同樣認為必須對於各種因素綜合判斷。

所謂「綜合」絕不可能是恣意的拼湊或隨興的聯想，須符合經

83 對此，如最高法院96年度台上字第4026號判決即有清楚的說明。

驗法則以及論理法則，依此，有必要釐清這些法則之具體內容，以之作爲審查事實審有無違法之標準。我國早期實務意見已經將判斷殺人犯意的步驟勾勒出來了，被害人所受的傷勢是判定的起始點，以此再另外找尋輔助之佐證，綜合考量以得到確定之心證。而依我國實務現今見解，各個因素在審查上並無優劣順序，其操作方式的實際面貌為何，有待進一步的釐清。就79年以來的最高法院判決進行概覽，以刑事第一庭、第五庭與第十庭為例（請參閱附件）⁸⁴，我們可以觀察到下列幾個重要指標：

（二）行為之背景

此部分之相關事實，包含行為人與被害人之關係以及行為人所受之刺激，而此部分之事實大抵構成所謂之犯罪動機。由於51年台上字第1291號判例已確立一個基本的立場：「不能因與被害人素不相識，原無宿怨，即認為無殺人之故意」，因此，在行為人與被害人毫無關係之情形，此一事實即屬中性，亦即毋須因此推斷行為人當無殺人之念，但也不應認為行為人無視於被害人之生死。依此，當需依賴其他因素始得判斷故意之相關問題，如91年度台上字第2669號判決⁸⁵。

然而，在相反的情況，最高法院則有不同的思考，亦即若行為人對於被害人具有情感上的依賴關係，即便痛下重手，也與其本意

⁸⁴ 由於與殺人故意有關之最高法院判決不計其數，為避免過於蕪雜，將判決依其庭別先進行初步之比較分析，但由於庭員並非固定不變，所以此種劃分並非絕對。另外，本文對於程序駁回判決之處理，並未一概排除，而是以上訴理由若實質上已涉及經驗、論理法則之爭議時，亦將其納入討論，核先敘明。

⁸⁵ 此一原則亦偶有例外，如最高法院82年度台上字第488號判決，認為「上訴人等與被害人並無仇隙，當時僅因與被害人酒後爭吵而聯手毆打被害人，且據上訴人林三和於偵查中供明僅在教訓被害人（見九五—八號偵卷第九頁反面），堪認上訴人等當時僅意在傷害被害人，並無殺人之犯意」。又如該院83年度台上字第3841號判決認為，「按上訴人等分別係錢櫃 KTV 店之股東或職員，與被害人本無深仇大恨，只因領取工程款及言語上之衝突而發生鬥毆，應無戕害生命或使之受重傷之犯意」。

有違，依此，可以反面地排除刑法第十三條第二項「不違背本意」之適用，故意即不成立，是故，此一部分之事實對於最高法院審酌意欲要素具有相當之決定性。例如95年度台上字第1774號判決中，行為人欲追求被害人，邀賞蜂炮遭拒，始因此雙方爭執而起意行兇。「是以案發當時被告與被害人之關係、爭執之原因等因素觀之，被告是否確有殺害被害人之故意，或有使被害人死亡亦不違背其本意之間接殺人故意，即非無疑，蓋此結果實違其欲追求被害人之本意」。

其次，最高法院審查下級審判決時，要求其必須具體交代行為人對於是否具有「殺意」，並認為此與行為人之攻擊行為無關，依其說明，應是將殺意視為行為人之殺人動機，例如94年度台上字第968號判決指出，「究竟上訴人為何要故意開車撞死被害人？如有殺人犯行，究竟係基於殺人之確定故意或不確定故意為之？上訴人稱其肇事時僅有學習駕駛證，尚未取得駕駛執照，而當時上訴人年甫滿十八歲，則上訴人所辯：因撞到人，心裡害怕，想趕快逃離，未看到被害人倒在何處，無殺人故意等情，是否屬實可採？原審就上開重要待證事項，未詳查釐清，即率行判決，顯有調查未盡之違誤」。此一見解似乎僅要求原判決切實釐清事實，然而，在本判決中，其實已經提到原判決的認定是，「基於殺人及駕車逃逸之犯意，明知王域清倒於其車前方，竟將自小客車倒車，再開車加速向前猛力衝撞王域清」。這樣說來，最高法院所要求的是，原審必須說明「基於殺人犯意」之認定所從何來。

此外，如最高法院96年度台上字第4026號判決指出，「至於上訴人是否基於『殺人』之犯意，持尖刀接續猛刺李燦群之左頸部……等處？並未於事實明白認定，則其理由說明上訴人有殺人之犯意，即失所依憑」，認為原判決雖已確證行為人持長形尖刀接續猛刺被害人左頸部、前頸部、左腹部、左腹外側部、左大腿後部及左手背部之舉動，但此仍非對於行為人具有殺意之說明。

如果我們將上述意見中的「基於殺人犯意」理解為殺人故意，那麼，上述判決應係要求原審必須切實說明故意之認定，以避免循環論證，用基於殺人犯意當理由推論行為人殺人故意。但是，讓我們需要進一步思索的是，原判決中所言對於行為實施方式之調查與論證，本即為綜合觀察法中不可或缺之部分，換言之，本即為審查殺人故意之重要部分。如果要求事實審除此之外要另外說明為何行為人乃係「基於」殺人犯意，無異要求其審酌行為人是否具有殺人動機。

（三）行為時之言語表示

最高法院在零星的判決中，提及行為人於犯罪進行之語言表示，而之所以是偶爾提及，應是由於此種事實本身不常出現之故。而值得注意的是，只要是行為人表示了類似「給你死」或「給他死」的語句，一般而言皆可作為強化行為人當具有殺人犯意之重要指標，例如最高法院80年度台上字第357、89年度台上字第4156以及91年度台上字第2669號判決。

例外之意見，如87年度台上字第4076號判決，最高法院考量被害人遭三行為人持刀包圍，卻僅受有多處輕微之瘀傷與擦傷，因此，即便「被告在場喊叫『給他死』，僅係嚇唬教訓上訴人之意，俟見教訓目的已達，即自行離去，難認有殺害上訴人之犯意，而僅係基於普通傷害教訓之犯意而為」。此一看法顯現綜合觀察法的優點，亦即不拘泥於單一性之因素，本判決之整體考量相當具有說服力。

較為特殊的是，最高法院於80年度台上字第3831號判決中指出，雖然上訴理由雖然指稱行為人具有殺人故意，因為其於他人毆打被害人時，在旁喊叫「給他死」。但最高法院則同意原判決意見，「即縱其事後說『給他死』之氣憤話，亦難認與王石村、陳志祥有共同傷害之犯意聯絡」，認為此判定合乎經驗法則與論理法

則，因此程序駁回上訴。此一推斷是否果真符合經驗法則與論理法則，仍有待商榷，因為以「氣話」當作是否定殺人故意之理由，並不充分，應當將焦點置於該表示之時點問題上，既然是事後才出此言，當已欠缺犯意聯絡之要件。

(四) 與被害人之傷勢相關之事實

對於與被害人之傷勢相關之事實，亦即犯罪工具、傷勢部位之所在以及攻擊力道等三項，最高法院在所有的判決之中都至少提及了其中一項，甚至有許多判決對於這三個要素皆予以討論者，例如79年度台上字第2440、80年度台上字第1066號等等判決，其數目可以說不勝枚舉，由此顯見此部分之事實對於故意認定之重要性。所以，我們可以認為最高法院在這個意義上延續了早期的實務意見。

然而，如果我們換至相反的角度來看，最高法院僅以上述三項要素之討論為滿足之判決亦屢見不鮮，例如上述之79年度台上字第2440號判決，其他如82年度台上字第968、89年度台上字第5657號等等判決，以及較為近期的如97年度台上字第5073號判決。其中79年度台上字第2440號判決謂：「查扣案之杉木棍，直徑十一公分，極為堅硬，經勘驗屬實。用以猛擊人之頭部，足以使人顱內出血死亡，此為上訴人所明知。竟持以猛擊被害人頭部四下，使被害人顱內出血當場死亡，足證其用力之猛，殺意之堅，顯有置被害人於死之故意」。又如87年度台上字第4514號判決謂：「依照原判決認定：被告一時氣憤，手扼曾女頸部，曾女因而氣絕身亡，而手扼被害人頸部足以使人死亡，在通常觀念上應有預見。則依原判決所認定，被告之行為是否無殺人之犯意？殊堪推求，此與以器械或拳腳對被害人打踢身體要害以外之部位，以致被害人發生不預期之死亡結果之情形迥異，原判決遽認被告扼被害人頸部之行為，係基於傷害之犯意，自嫌速斷」。上述的論證方式雖然確有其經驗與論理法則上的根據，但是，對於綜合觀察法來說卻是有疑義的，因為，既

然是「綜合」審查，當須一併斟酌其他因素。是故，若僅以與傷勢有關之要素作為立論之唯一根據，則所謂的「綜合觀察法」在實際的操作上並未落實，恐難認為係一「綜合」之考察方式。

四、綜合觀察法之疑義

（一）判斷方式不明確

最高法院對於綜合觀察法的操作，仍不能謂已臻明確。首先，正如前述已經指出的是，99年度台上字第2092號判決中所謂「應參酌行為當時所存在之一切客觀環境」，如果是指其所例示之「行為人因何原由逞兇，行為當時之手段是否猝然致被害人難以防備，攻擊時之力勁是否猛烈足資使人斃命，及攻擊所用之器具、攻擊部位、次數、用力之強弱、被害人受傷之部位、程度」，按此，只是一個相當籠統的判斷方式，所參考的因素之間的關聯性為何，仍付之闕如。不意外的是，如此一來，將可能在個案中造成某一因素獨大的情形，如97年度台上字第5888號判決雖然指出：「加害人之下手情形如何，於審究犯意方面，仍不失為重要參考資料」，但是，在實際上卻是以行為人於毆打被害人之後的舉止為由，亦即停手後未再毆打並陪同被害人就醫，以此質疑原判決肯定殺人故意之正當性。

其次，就被害人所受傷勢之所在與程度而言，實務上對此之認定仍陷於紛亂。以95年度台上字第1774號判決為例，被告持蝴蝶刀朝被害人之後背部刺擊，被害人因左腰背近外側受刀刺深及右肺下葉，導致大量出血而死亡，就此，原判決臺灣高等法院臺南分院認為，該傷勢所在部位，並非如頭部、前胸部或後背部等內含關乎生命存否之要害器官之部位，以此作為否定殺人故意之論據。但臺灣高等法院臺南分院檢察署則於上訴理由書中指出，甲持刀攻擊之位置，雖非頭部、前胸部或後背部等內含關乎生命存否之部位，然人

體之腎臟及肺葉亦屬人體重要器官，皆可能因刺擊而大量出血死亡，而行為人之攻擊位置，6刀中有4刀都命中被害人此部分範圍。針對此一爭議，最高法院並未予以釐清，僅謂「按取捨證據及認定事實，乃事實審法院職權之行使，其對證據證明力所為之判斷，苟係基於吾人日常生活之經驗，而未違背客觀上應認為確實之定則，並已敘述其何以為此一判斷之理由者，即不能指為違法」，支持原判決之認定，此一理由上的省略，將可能造成綜合觀察法在操作上的第一步即已陷入泥淖。

針對上述之質疑，或許最高法院會指出，由於其法律審之定位，僅需針對事實審有無違背經驗法則與論理法則之部分進行審查，毋庸進行事實之認定，因此，針對殺人故意之認定問題，僅就疑有悖於上述法則之部分論斷即可。然而，按照最高法院本身對於綜合觀察說之詮釋，此一故意之認定本即一具有單一性之整體判斷，實無法割裂而僅檢驗其部分，換言之，綜合觀察模式已經構成了一個論理的法則，要求在故意的認定上必須進行多重因素的統整，所以，僅審酌部分因素之作法其實已違背論理法則。況且，以79年度台上字第1638號判決為例，被告否認其具有殺人故意而上訴，而最高法院贊同原判決之意見認為，被害人甲「被刺殺致胸部穿刺傷併氣血胸休克」，而被害人乙「雙側氣胸、腹內出血、腸子外流休克」，因此認定「上訴人具殺人犯意，至為明顯」，不能謂已確實逐一地踐履綜合觀察法之審查方式。

較為特殊的是96年度台上字第1244號判決，行為人持木劍攻擊被害人，使其受創倒地後，因聞警車鳴笛將至，為免於遭受逮捕，隨即逃離現場，而倒臥於機車道與汽車道中間之被害人，不幸被警車輾壓拖行而死亡，最高法院指出「參酌被害人遭毆傷後之倒臥處車輛來往頻繁，被害人隨時有遭行經該處之車輛輾壓致死之危險，此應為常人所能預見，上訴人於警詢及檢察官偵查中亦供承有此預見，上訴人自負有防止危險發生之義務，且依當時情況亦無不能防

止之情事，僅因擔心為警查獲即逕自離去，對被害人未為任何防止危險發生之行為，堪認上訴人確有殺人之不確定故意」。此一說明針對的是行為人離去而不作為之部分，所以與一般作為犯的檢驗方式不同，而在故意的審查上，僅著重於行為人是否知悉被害人身處之所在，至於與意欲要素有關之部分，似未詳述認定之理由，因此，其是否逐一地進行綜合性之審查，頗成疑問⁸⁶。

（二）論證之歧異

以蝴蝶刀刺傷殺他人為例，在最高法院95年度台上字第1774號判決中，被告持蝴蝶刀之利刃，刺穿被害人左手臂，且自後刺擊被害人背部深及肺部，對於原判決臺灣高等法院臺南分院之見解，該傷勢所在部位並非內含關乎生命存否之要害器官之部位，並以此作為否定殺人故意之論據，最高法院認為該意見與經驗及論理法則並無違背，已如上述。然而，其後於97年度台上字第5179號判決中，行為人亦持蝴蝶刀作為犯罪工具，一時氣憤下將情敵刺死，最高法院卻反而認為：「蝴蝶刀為鋒利之刀械，以之往人體要害部位刺殺，足以奪人性命，其他部位若揮刺過猛，深及體內臟器，亦可致人於死，又肩胛靠近胸腔，胸腔內有心臟、肺臟等人體重要器官，以利刃自人之肩胛部位往下，可刺入胸腔，為眾所周知之事實，自亦為上訴人所明知。上訴人竟持扣案之蝴蝶刀刺殺被害人洪錦守，造成被害人全身六處銳器傷，其中一處自左肩部刺入，途徑長10公分，以向右向下45度略向後之方向，刺入左胸膛，刺中左上肺葉表面0.5公分，造成血胸，內含血液800C.C.，為致命傷，死亡方式為「他殺」，有法務部法醫研究所解剖鑑定報告在卷可稽，足見上訴人下手甚重，原判決因認其有殺人之犯意，論以殺人罪責，並無不合」。

⁸⁶ 本判決事實與最高法院94年度台上字第246號判決有相似之處，但該案以傷害致人於死罪確定。

將上述最高法院的兩個判決相互對照，兩者相同之處在於，皆是以蝴蝶刀刺傷他人，在犯罪工具上來說是一致的，並且被害人都因刺傷肺部而導致傷重不治。兩者相異之處，僅在於刺入之部位有所分別，也因此有不同之認定，一方面最高法院對於刺擊被害人背部深及肺部之情形，認為可以以此傷勢所在部位否定殺人故意；但是，在另一方面，卻又認為若自肩胛部位往下刺入而刺中肺葉時，即為被告具有殺人犯意之明證。如此，最高法院對於極為相近之事實卻作出結論相左的論斷，而理由則未臻明確，使人若墜入五里霧中，不知何者係符合「經驗法則及論理法則」。若是完整按照綜合觀察法，關於傷勢之判斷僅是判斷程序的起步而已，起步若此，則殺人故意之認定將可能陷入迷濛之中而喪失其可預測性。

(三) 行為動機與背景之意義？

與德國實務相較，我國最高法院並未對於殺人故意建立類似梗阻理論的判斷方式，也因此避免陷入心理主義的泥淖之中，這一點固然值得肯定。但是，這仍不表示我國實務可以免於判斷行為人心理之困擾，尤其我國刑法第十三條關於「有意」與「不違背本意」之實體要件規定，在程序上仍須透過證據之調查及判斷形成心證，然而，我國實務對於本意之問題，卻深陷行為人的心理迷霧之中。

實務上部分判決對於18年上字第1309號判例所言之「殺意」解釋為殺人動機，我們若觀察該判例所言，「殺人與傷害人致死之區別，應以有無殺意為斷」，那麼，此一解讀將造成的後果是，行為動機是唯一區分殺人與傷害人致死的標準，這不但有悖於綜合審查法不拘於單一指標之思考，而且又回到一個老問題上，亦即這種主觀內心的事實如何能探究？就行為動機本身論之，倘若行為人與被害人之間，果真存在某種仇怨或衝突，這一點也根本無法當作行為人懷有殺人動機之理由，因為，仇怨或衝突也可以成為一個人傷害他人身體或健康的動機，是故，這一點無法作為認定犯罪動機之唯一根據。

此外，針對行為背景與「本意」之間的關係，實務的連結方式仍有待斟酌。例如在最高法院95年度台上字第1774號判決中，原判決認為，行為人乃係欲追求被害人遭拒，因此雙方爭執而行兇，則死亡之結果有違其欲追求被害人之本意。原判決並以行為人促使被害人出面之恐嚇言語，僅係促使被害人至其住處商談之手段，應非確有殺害被害人之意，因若已存殺人之意，衡情當不會事先告知，使之有所防備，甚或拒絕前來會面，況且被害人亦依約至被告住處與之商談，已達甲前揭恫嚇言語所欲獲得之目的。除此之外，原判決指出行為人雖事前備妥蝴蝶刀置放於車內，然備置蝴蝶刀之舉，可能性甚多。持以傷害、殺害甚或恫嚇被害人均不無可能，故不能僅以事先備妥蝴蝶刀之行為，即認其本存殺害被害人之意。而其於行兇見被害人倒地後，即駕車離去，不將被害人送醫急救，乃一般行兇者害怕被發現犯行之通常反應，其既無另行將被害人移位至他處使之不易被發現，則自無消極殺人之犯意⁸⁷。

對於上述意見與推論，最高法院在判決中認為其符合論理與經驗法則，但是在理由上則是付之闕如，其說服力恐頗有不足之處。舉其中之一而論，追求不成惱羞成怒憤而持刀殺人者所在多有，如何能謂死亡之結果「有違其本意」，若果依此推論方式，則家人親屬之間甚或是朋友之間，都可以用同樣的說法主張被害人之死亡對於行為人來說「有違其本意」，因為，兩者之間存在著更加親密的關係，若非一時氣急攻心不致若此，死亡之結果使得行為人痛苦悔恨萬分，此亦當與其本意有違。但是，若果真如此推論，那麼，不計其數的最高法院判決將被推翻，所有具備親友關係的案件皆應排除殺人故意之成立，甚且，按照此一推論可以更進一步排除傷害故意，因為，造成親友受到傷害也會讓行為人感到痛苦不安。依此，在親友之間，有那一種侵害專屬性法益之犯罪故意是可以成立的呢，這樣的說理實難謂與論理法則符合。

87 請參閱，臺灣高等法院臺南分院94年度上訴字第1106號判決。

綜合上述本文之說明，我們可以初步看出，我國實務之綜合觀察法顯現了在實際個案中進行故意認定將會出現的特殊性，亦即我們似乎無法在事前找到一個鉅細靡遺的判斷準則，或者可以說，因為難以一概而論，所以並無一個具有普遍性的判斷或判斷方式。然而，這樣的結論無法讓人感到滿意，因為，如本文所指出的，我國實務的個案判斷中存在過多的疑問，此與法安定性的要求仍有一段差距。

陸、檢討與建議

一、對於學說與實務之反思

(一) 故意作為法律概念

我們已經習慣於以日常生活語言理解何謂故意、認識及意欲。但是，這樣的理解方式與故意作為法律概念有所不同，日常生活語言中的故意，往往是著眼於行為人做一件事的出發點，是在描述一種人作為生物的情緒狀態。但是，作為主觀構成要件的故意與過失，則是將客觀結果之法律責任歸諸於行為人，所涉及的是規範性的評價，這一點與客觀構成要件中的客觀歸責或相當因果關係並無二致。因此，例如等價客體錯誤之情形，雖然行為人對於客體之同一性發生錯誤，但不影響其故意歸責，反之，在因果歷程錯誤之情形，即便最終的結果就是行為人一開始所追求的，也可能因為客觀上的因果偏離具有重要性，而排除結果之故意歸責。既然故意是一個法律概念，是構成要件實現的主觀歸責，相較於過失，故意是一種特別值得予以非難的歸責型態，必須對於構成要件之實現負完全之責。

反之，如果我們將故意及其要件視為心理狀態，其實到頭來會

發現，心理學上對於心理流程之理解，與法律的概念範疇少有契合之處。而且更重要的是，一個人在某個事件的發展過程中，他對於行為結果之好惡情緒其實可能是流動而不穩定的，而認知與意欲之間的關係，則是相互纏繞而糾結不清，像是一個遍尋不著出口的叢林⁸⁸。而問題的癥結在於，我們不能混淆法律評價的標準與評價對象兩者，質言之，行為人的心理狀態是要被評價的客體，是我們判斷是否成立故意所要予以審酌之對象，但是，此一心理現象本身並非判斷標準。我們也可以從另一個角度切入，既然故意是不法構成要件的一部分，那麼，除了故意是以不法之犯罪事實為其內含之外，故意本身更是一個犯罪的靈魂，操控著犯罪行為之進行，換言之，故意並非是受到外界變化所被動引發的感官活動（知覺、好惡）⁸⁹。

按照我國刑法第十三條之規定，認識與意欲是兩個故意在成立上所必須具備之要素，所以，接下來的問題是，認識與意欲是否也是心理現象呢？為了回答這個問題，也許可以回到刑法的基本思考做一個類比：對於刑法上諸如「強暴」、「竊取」，甚至簡單如「殺人」之概念，我們不會認為這僅是一個物理現象而已，因為這些概念是否被滿足，都必須要以規範性之標準進行對於客觀事實之評價。同樣的，在腦海中浮現何種意識現象才能夠被稱之為「認識」⁹⁰，最明顯的是行為人對於規範性構成要件要素，如「文書」

88 相關文獻之整理，見：Walter Perron, Vorüberlegungen zu einer rechtsvergleichenden Untersuchung der Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit, in: Festschrift für Haruo Nishihara, 1998, S.145 (154)；德國學者 Frisch 即曾指出，若我們將故意的認識要件與心理學上的「意識」概念相連結，不但徒勞無功，而且將會是治絲益棼之舉，vgl. Wolfgang Frisch, Vorsatz und Risiko. Grundfragen des tatbestandsmäßigen Verhaltens und des Vorsatzes. Zugleich ein Beitrag zur Behandlung außertatbestandlicher Möglichkeitsvorstellungen, 1983, S. 165.

89 Vgl. Detlef Krauß, Der psychologische Gehalt subjektiver Elemente im Strafrecht, in: Festschrift für Hans-Jürgen Bruns, 1978, S.11 (21 f.).

90 何謂故意要件之「認識」，尤其是針對妨害未成年成年人自主之犯罪，行為人對於被害人之年齡應有何種「認識」，在文獻上較為深入之討論，已見 Winfried

或「他人動產」等，是否具有意義上的認知與理解，亦即是否已具備所謂的「外行人之平行評價」⁹¹；而行為人懷有如何的情緒才能夠被評價為「同意」、「容任」，在在都不是直接由心理現象決定，而是須要進行規範性之判斷，而此一判斷之基礎，還是與故意作為一較重之主觀歸責型態息息相關。而如何方能構成「認識」與「同意」的問題，可以從對於意欲理論與認識理論的反省入手。

(二) 認識理論與意欲理論之疑義

意欲論者在過去對於未必故意的意欲要素應如何認定，確實耗費許多心力，諸如「接受」、「容任」、「同意」、「漠然」等等意見一一出籠，而對於我國來說「不違背本意」被普遍認為其意義相當於「容任」，所以，我們也無法置身事外。上述這些理論爭執不休的根本原因，還是在於心理現象與規範標準之混淆，例如在皮帶案中，行為人在心理上對於被害人的死亡是不樂見的，那麼，這是否就意味著行為人對於結果並未「接受」、「容任」、「同意」以及「漠然」呢？類似的疑問也出現在最高法院95年度台上字第1774號判決一案中，行為人追求未果而持刀砍殺，既有追求之意，這是否就意味著行為人對於結果並未「接受」、「容任」、「同意」以及「漠然」呢？

對於上述的兩個問題，答案都應該是否定的，因為，行為人在確知其行為具有高度危險性之前提下，還是決定採取此一行動，既然這是一個經過思慮的行為，行為將可能導致的結果當然也屬於行

Platzgummer, Die Bewußtseinsform des Vorsatzes: eine strafrechtsdogmatische Untersuchung auf psychologischer Grundlage, 1964, S. 3 ff.; Paul Bockelmann, Bemerkung über das Verhältnis des Strafrechts zur Moral und zur Psychologie, in: Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch, 1968, S. 252 (254 f.); Frisch, (見註88), S. 162 ff.; Horst Schlehofer, Vorsatz und Tataabweichung, Zur Auslegung der §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 22 StGB, 1996, S. 154 ff.

⁹¹ Ingeborg Puppe 著，許玉秀譯，〈構成要件錯誤與包攝錯誤〉，《政大法學評論》，55期，頁199以下（1996年6月）；黃榮堅，《基礎刑法學（上）》，頁452以下（2006年9月修訂版）。

為決定之一部分，因此，不能因為行為人在情緒上厭惡結果之發生，即謂此結果與行為決定無關。更進一步來說，如果我們在法律上是將一個人視為具有理性之主體，其身為理性主體而對於其行為負責，那麼，我們要判斷的是，一個有理性之人居於行為人之地位時，是否此一行動決定就意味著「接受」或「同意」了結果之發生，換言之，在這裡要忽略的是，行為人基於個人情緒之好惡而對於結果所抱持之態度。同樣的，在審查所謂「信賴」結果不發生時，並非行為人有此想法即可謂具備此一要件，如同我們在德國實務中所看到的，應該使用的檢驗標準是，是否在該個案中，行為人具有合理之信賴，若僅為單純的樂觀或心存僥倖，皆非構成排除故意之信賴。

認識論者主張因為意欲要素難以判定，所以予以放棄，且主張大可忽視其存在，因為，行為人預見其行動將造成的結果卻仍為之，即是對此結果具有意欲。此一見解雖然確實點出了問題，但是，卻像是一種鋸箭法，僅在表面上解決了一個困境，卻沒有根本地將故意的全部的要素予以釐清，彷彿可以簡單地將認知與意欲之間的關係一刀兩斷。而更值得注意的是，若如認識論者僅檢驗行為人之認知，將不得不提高此一認識上的要求，以避免故意成立之浮濫，如此一來，或者提高風險認識之高度，如 Puppe 所提倡之故意風險理論，要求行為人認識其行為在經驗上適合於導致結果之發生，但是，此一要求與德國普遍承認之故意類型——意圖故意 (Absicht)⁹²無法相容，因為此種故意僅偏重在意欲要素之檢驗。或者認識論者改為審酌行為人看待風險之態度，然而此一態度之審究，已與意欲要素之檢視難以區分。

若持認識說而對於行為人之預見並無程度上之要求者，從故意

92 亦有譯為「蓄意」者，林鈺雄，前揭（註43）書，頁189。關於此種故意之介紹，亦請參閱：徐育安，前揭（註14）文，頁38。

認定之角度言之，很容易可以就能透過一些外在的事實來證明行為人之預見，在個案的判斷上較無困難。不過，此種認識說在理論上被認為其缺陷在於，我們不能單純以淡薄之認識而令行為人負極重之故意責任。而在故意認定上，此一判斷標準勢必將極度擴張故意成立之範圍，有認識過失固然皆會被認定成立故意，甚至無認識過失之情形，也將因為本說不要求認識程度，而被輕易地認定成立故意，例如，對於一個倒車時沒看照後鏡而壓傷他人之駕駛，可以用「倒車不看照後鏡可能會壓傷他人，這是任何人都知道的事」，作為成立故意之論據，類似的情形如，任何人都知道「十次車禍九次快」、「子彈不長眼」。換言之，因為一般人都有對於風險之基本常識，這樣的常識將會被作為論據，證明行為人起碼具有淡薄之認識，並因而負擔故意之責任⁹³。

二、建議（代結論）

基於上述的分析與檢討，可以初步對於實務之操作提供下列幾點淺見：

（一）綜合觀察法之再思考

首先，筆者對於綜合觀察法基本上抱持肯定的態度⁹⁴，因為，我們的確無法以單一性之因素即論斷刑法上的故意之是否成立，因此，有必要在考量時納入多項指標。不過，本文要強調的是，這裏所謂的「綜合」絕非意味著一種量化後的加總，亦非進行一種類似拼圖遊戲的重組工作，在德國學界曾有學者嘗試提出一種綜合性的審查法，其完整蒐羅各項與認識及意欲有關因素指標，並建構一套

93 相近之批評，已見黃惠婷，〈故意與構成要件錯誤〉，《月旦法學教室》，72期，頁75（2008年10月）。

94 我國學者甚至認為，「綜合說是唯一可行的辦法，也是唯一已經實踐的辦法」，許玉秀，前揭（註38）文，頁156；相近之說明，亦見蔡蕙芳，〈故意犯罪（一）——直接故意與間接故意〉，《台灣本土法學雜誌》，72期，頁166、171-172（2005年7月）。

數值分析的審查模式，以此促進故意判斷的客觀化，但其也指出，終究各個指標的數值為何，以及其數值之調整，甚至劃分故意與過失之臨界值為何，皆仍須依賴人的法感(Rechtsgefühl)決定之⁹⁵，而此一法感當不能依賴單純的直觀決定之，而須以故意在刑法上的意義思考判斷之標準。因此，為了避免綜合論成為欠缺章法的拼湊，甚至可能淪為恣意判斷的障眼法，本文建議應當建立一個判斷上的明確順序，並視情況將與刑法評價無關之部分去除。

在綜合觀察法的判斷次序上，最高法院早期以傷勢作為後續判斷之起始點，已經顯現出一種具有階段性的檢驗方式，但是，這一個作法尚非一已然確定之方式，以現今之實務判決來說，未循此方式之判決仍不時出現。對於殺人故意之認定來說，行為人以如何之方式進行攻擊，是刑法的評價上最為核心者，因為，在刑法第二七一條中，立法者僅以「殺人」作為其全部之明文構成要件，因此，攻擊之工具、力道與部位傷勢三點，其實本身即為構成要件行為與結果之體現方式。

與上述之要素相較，行為人與被害人之關係、犯罪之背景、行為時之語言表示以及是否在被害人受傷後仍續行傷害，則為補充性之事實，所以，在檢驗的次序上屬於劣位者。當然，按照這一個優劣位之區分，當後者之意義與前者相互矛盾衝突時，仍應以優位之事實為準據。舉例言之，在前述空手道武者之案中，毆擊之方式、力道與部位所顯示出之意義，亦即行為人殘暴而視被害人幼小之生命如草芥；但是，行為人平日卻對其悉心照料，且於行為後予以施救，似乎對於被害人之安危頗為關心。上述兩個部分的事實所顯示出的意義頗有衝突，而依照優劣位之區分，應當以前者之意義為準據。另外，其他之因素則屬更為劣位者，亦即雙方之抗衡比例以及

95 Lothar Philipps, An der Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit — Ein Modell multikriterieller computergestützter Entscheidungen, in: Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag, 2001, S. 365 (365 ff., 376 f.).

犯罪處所等事實；而犯後之舉止，則非評價範圍所及，當無庸予以審查。

(二) 建議之審查方式

以此一具有階段性的檢驗方式為基礎，本文的出發點是，既然我國刑法已對故意之定義有所規定，即已賦予一個明確的方向，司法者必須就犯罪事實之知與欲這兩個要件予以審查，那麼，綜合觀察法的思考方向即須針對於此，這一點實務其實亦已清楚意識到，但是，卻經常藉由犯罪事實以外之事實納入考量，紊亂了知與欲原本應當包含的對象。例如在前述最高法院95年度台上字第1774號判決中，原判決側重於行為人與被害人之追求關係，並以被害人被逼迫而赴約，既達恫嚇所欲獲得之目的，即無起殺意之必要，但是，卻又在最後將逞兇後離去解釋為一般行兇者害怕之通常反應，如此一來，行為人「追求不捨」在前，「逃之夭夭」棄之不顧在後，那一個說法可以證明行為人對於被害人死活之心態呢？而且，這裡可以看出，判決理由所針對的是，被害人死亡後所產生的效應，而非行為有無可能造成死亡，此種後續效應若果真重要，我們是否可以說，如果行為人會害怕被害人死後的牢獄之災或是輿論指摘，所以死亡結果當有違行為人之本意呢？

延續上述，我們要檢驗的是行為人就犯罪事實之知與欲，但是，這兩個要件並非就是兩個有待發現的心理事實而已，這一點需要進一步加以說明。在行為人自承其具有殺人事實之知與欲的情形，可以先撇除不談。而對於較有爭議之情形，本文建議之審查程序，區分兩個階段如下：

1. 第一階段

所要檢驗的是與被害人傷勢相關之事實，亦即亦即犯罪工具、傷勢部位之所在以及攻擊力道等三項。若係重大傷害導致死亡的案

例，主要審查之對象為認識之要件，此處所需著重的是行為人是否對於其本身之行為性質已有所認知，例如其持一鋒利之工具而傷及被害人之重要部位（上半身或頭部），若其已對該行為本身有所認識，則事實審法官推斷其對於被害人之死亡亦有所預見時，即無違反經驗法則與論理法則。並且，在此種行為人認識其舉止有高度致命性之情形，被害人之死亡結果即可歸責於行為人，自應適用故意殺人既遂之規定，因為，此時行為人之行為意志（進行高度致命性之行為），已將對於被害人死亡之容任包含其中，是故，法律上可以將該結果歸諸於行為人之意志，換言之，毋須另外再對意欲要素進行審查，除非是為了要確認是否成立第十三條第一項之直接故意。

反之，若行為人對於自己的行為之瞭解，雖已預見其將造成他人生命上的風險，但是尚不具有高度致命性時，則必須另行針對意欲要素進行審查，亦即進入第二階段之討論。

2. 第二階段

此部分所要檢驗的是，行為人有認識地製造了被害人死亡的風險，是否可以將死亡結果評價為係行為人所容任或接受。就此意欲要素檢驗的積極部分來說，首先需要審視的是，行為人與被害人之關係以及行為人所受之刺激等，亦即關於犯罪動機之事實。不過，動機僅能提供一個方向性的指標，因為，不論是出於仇恨抑或是嫉妒，顯示的是攻擊行為之背景與原因，但其確切之目的究竟是殺人還是傷害，尚無法由此得知。而在無法獲知行為人的犯罪計畫時，在論理上所要審查的是，行為人是否於行為時一心只在其所欲達成之某種目標，如為宣洩一時之憤或滿足私慾，卻置被害人之生死為次要考量，而此蔑視他人生命之行事態度，方為刑法主觀歸責所要評價之終點。依此，即能較清楚地將審查意欲要素的判斷集中在行為人的侵害意志上，而如行為人與被害人平日的關係為何，則與此

並無甚關連，僅屬補充性之事實。

其次，行為人於犯罪時所為之語言表示，以及是否在被害人受傷後仍續行不斷地傷害被害人，當亦屬判斷意欲要素之參考事實，可作為審視行為人是否對於被害人之生命懷有敵意或視之如草芥之指標。而若行為人曾有防果行為時，本文認為許多學者過度強調其意義，實則，若是此種行為確係具有防果實效者，亦即有效降低死亡風險時，被害人當不至於死亡，本即毋須討論死亡結果應適用故意殺人或傷害致死之規定；反之，不具實效之防果行為，例如在德國的皮帶案中，被害人因高度危險行為而死亡，那麼，行為人即便曾為之防果行為並不具有評價上的意義。而行為後方始進行之防果行為，屬於犯罪後之舉止，例如事後送醫之行為，則非評價範圍所及，自毋須予以審查。

最後，在第二階段扮演消極要件角色的是，行為人對於結果不發生之信賴，對此一要素，仍須進行規範性之思考，而不能以心理事實為標準。具體言之，倘若行為人單純地相信一個不切實際的好運或技能，那麼，這樣的一個心理上的信賴，當不足以作為否定行為人容任結果發生之理由，因為，此種心態正好反映了他對於他人法益毫不在意。因此，僅只確有所本之信賴，呈現了行為人的慎重態度時，始能作為否定意欲要素之根據。

以上，係本文自刑法實體上之學理出發，提出在實務程序上的初步審查建議，或仍多有粗糙之處，僅盼能收拋磚引玉之效，供為實務與學界先進參考。

附件一：最高法院刑事庭第一庭判決分析
(製表：陳慶鴻、李慧盈)

判決理由之綜合觀察法分析											
年度	判決字號	各項判斷要素									
		1. 與被 害人之關 係	2. 行為 前後 或行 為中 所受之 刺激	3. 行為 時之 語言 表示	4. 犯罪 工具	5. 傷勢 所在	6. 攻擊 之度 與兇 猛程 度	7. 犯罪 處所	8. 是否 續行 傷害	9. 行為 後之 處置	10. 雙方 抗衡 比例
79	79 台上 2440				✓	✓	✓				
	79 台上 2870				✓	✓	✓				
	79 台上 4069				✓	✓	✓				
	79 台上 4751			✓	✓	✓	✓		✓		✓
80	80 台上 104				✓	✓					
	80 台上 1066			✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	80 台上 1729		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	80 台上 3112				✓	✓	✓				
	80 台上 5846	✓		✓		✓	✓				
82	82 台上 674			✓	✓	✓	✓		✓		
	82 台上 968				✓	✓	✓				✓

83	83 台上 5424				✓	✓	✓				
	83 台上 957				✓	✓	✓				
	83 台上 5647				✓	✓	✓				
84	84 台上 3179		✓			✓					
85	85 台上 5403	✓	✓		✓	✓	✓		✓		
86	86 台上 3619	✓	✓			✓		✓			
	86 台上 2777		✓		✓	✓		✓			
87	87 台上 255	✓	✓		✓			✓	✓	✓	
	87 台上 455	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
	87 台上 2675				✓	✓	✓		✓		
	87 台上 3768				✓	✓	✓			✓	✓
	87 台上 4076			×	✓	✓	✓		✓		✓
	87 台上 4257					✓	✓			✓	
	87 台上 4514		✓			✓					
88	88 台上 2707					✓	✓				
	88 台上 3737			✓	✓	✓					
	88 台上 7320				✓	✓	✓		✓		

附件二：最高法院刑事庭第五庭判決分析

(製表：陳慶鴻、李慧盈)

判決理由之綜合觀察法分析											
年度	判決字號	各項判斷要素									
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		與被 害人之關 係	行為 前後 或行為 中所受 之刺激	行為 時之 語言 表示	犯罪 工具	傷勢 所在	攻擊 之力度 與兇猛 程度	犯罪 處所	是否 續行 傷害	行為 後之 處置	雙方 抗衡 比例
79	79 台上 1638					✓					
	79 台上 1860				✓	✓	✓		✓		
	79 台上 2051				✓	✓	✓				
	79 台上 2400						✓		✓		
	79 台上 2718				✓	✓					
	79 台上 3154				✓	✓	✓			✓	
	79 台上 3780				✓	✓	✓				
	79 台上 3880					✓					
	79 台上 4172				✓						
80	80 台上 357			✓		✓					
	80 台上 1015					✓	✓				

	80 台上 1121				✓	✓	✓		✓		
	80 台上 1703					✓					
	80 台上 2134				✓	✓			✓		
	80 台上 2506				✓	✓	✓				
	80 台上 2957						✓		✓		
	80 台上 3831		✓	✕	✓						
	80 台上 4408				✓	✓	✓		✓		✓
	80 台上 5745				✓	✓	✓				
82	82 台上 488	✓	✓								
	82 台上 2150				✓	✓					
	82 台上 5125				✓	✓	✓		✓		
	82 台上 5649	✓	✓			✓	✓		✓		
83	83 台上 2984					✓			✓		
	83 台上 3557				✓	✓				✓	
	83 台上 3711			✓		✓	✓				
84	84 台上 67				✓	✓	✓				
	84 台上 685			✓	✓	✓	✓		✓		

	84 台上 853				✓	✓	✓		✓		
	84 台上 2880	✓	✓		✓	✓					
	84 台上 4556				✓	✓	✓				
	84 台上 5427					✓			✓		
85	85 台上 374				✓	✓	✓		✓		
	85 台上 4345				✓		✓				
86	86 台上 4623				✓	✓					
	86 台上 3489		✓	✓	✓	✓					
	86 台上 2790	✓	✓		✓	✓		✓			
	86 台上 1494	✓		✓		✓		✓			
	86 台上 355		✓		✓	✓				✓	
	86 台上 352	✓	✓		✓			✓		✓	
87	87 台上 1191				✓	✓	✓		✓		
	87 台上 3976				✓	✓	✓				
	87 台上 4224				✓	✓	✓				
88	88 台上 2579			✓	✓	✓	✓				
	88 台上 5842			✓		✓			✓	✓	

	88 台上 5846				✓	✓	✓		✓	✓	
	89 台上 430	✓	✓		✓	✓					
	89 台上 2203				✓	✓	✓				
	89 台上 2883				✓	✓	✓			✓	
	89 台上 3340				✓	✓					
89	89 台上 3692					✓	✓				
	89 台上 5411					✓	✓				
	89 台上 5574				✓	✓	✓				
	89 台上 6163	✓			✓	✓				✓	
	91 台上 1226		✓		✓	✓	✓				
91	91 台上 4191				✓	✓					
	92 台上 430		✓		✓	✓			✓		
	92 台上 1080				✓	✓					
92	92 台上 3171			✓	✓	✓					
	92 台上 4472				✓	✓	✓				
	92 台上 4976				✓	✓					
93	93 台上 925			✓	✓	✓					

	93 台上 3515		✓		✓						
	94 台上 4023				✓	✓					
94	94 台上 5355	✓	✓		✓	✓	✓				
	95 台上 1219		✓		✓	✓	✓				
95	95 台上 1805	✓	✓		✓	✓					
	97 台上 5884	✓	✓			✓	✓		✓		✓
	97 台上 895	✓	✓		✓	✓	✓		✓		
	97 台上 3293	✓			✓	✓	✓		✓		
	97 台上 3862					✓	✓				
97	97 台上 4607	✓	✓		✓	✓	✓				
	97 台上 5757			✓		✓	✓		✓		
	97 台上 5888					✓				✓	
	97 台上 5892				✓	✓	✓				
	97 台上 6067					✓	✓				
	98 台上 1852				✓	✓	✓				
98	98 台上 3618	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	98 台上 5531		✓		✓	✓					
99	99 台上 2367		✓		✓	✓	✓		✓		

附件三：最高法院刑事庭第十庭判決分析

(製表：陳慶鴻、李慧盈)

判決理由之綜合觀察法分析											
年度	判決字號	各項判斷要素									
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		與被 害人之關 係	行為 前後或 行為中 所受之 刺激	行為 時之語 言表示	犯罪 工具	傷勢 所在	攻擊 之力度 與兇猛 程度	犯罪 處所	是否 續行 傷害	行為 後之 處置	雙 方 抗 衡 比例
82	82 台上 3074				✓	✓					
	82 台上 5046			✓	✓	✓	✓				
83	83 台上 2438					✓			✓		
	83 台上 2786	✓	✓			✓					✓
	83 台上 2789					×					
	83 台上 3841	✓	✓								✓
85	85 台上 6083					✓	✓		✓		
86	86 台上 7502		✓		✓	✓					
	86 台上 6914	✓	✓		✓	✓					
	86 台上 2835		✓	✓	✓	✓		✓			
	86 台上 2198		✓		✓	✓			✓		

	86 台上 1609	✓	✓	✓	✓	✓					
	86 台上 1439		✓		✓	✓	✓				
	86 台上 845		✓		✓	✓				✓	
	86 台上 400		✓		✓	✓	✓				
87	87 台上 2047				✓	✓	✓				
	87 台上 2627				✓	✓	✓				
	87 台上 3720					✓	✓				✓
	87 台上 3922					✓	✓				
88	88 台上 554		✓		✓	✓	✓		✓		
	88 台上 4985		✓			✓					
	88 台上 5732		✓		✓	✓	✓		✓		
	88 台上 6399	✓	✓			✓	✓			✓	
89	89 台上 4171					✓	✓				
	89 台上 4402			✓	✓	✓	✓		✓		
	89 台上 5187				✓	✓	✓				
	89 台上 6412				✓	✓					
90	90 台上 335	✓	✓		✓	✓					

	90 台上 2856		✓		✓	✓			✓		
91	91 台上 1910		✓		✓						✓
92	92 台上 4887		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
94	94 台上 968		✕		✕	✕		✕	✕		
	94 台上 2551		✓	✓	✓	✓			✓		
95	95 台上 959		✓		✓			✓			
	95 台上 1160				✓						
	95 台上 1774	✓	✓		✓	✓	✓				
	95 台上 4480				✓	✓	✓				
96	96 台上 4026		✕		✕	✕	✕				
97	97 台上 2972	✓			✓	✓	✓		✓		
	97 台上 3852		✓		✓	✓	✓		✓		
	97 台上 5073					✓	✓				
	97 台上 6428		✕		✓	✓	✓	✕			
98	98 台上 1778				✓	✓	✓				

參考文獻

1. 中文部分

- Ingeborg Puppe 著（1996），許玉秀譯，構成要件錯誤與包攝錯誤，
政大法學評論，55期，頁195-205。
- 林山田（2008），刑法通論（上），增訂十版，台北：自版。
- 林鈺雄（2011），新刑法總則，三版，台北：自版。
- 柯耀程（1998），論加重結果犯，林山田教授紀念論文集編輯委員會編，罪與刑——林山田教授六十歲生日祝壽論文集，頁131-164，台北：元照。
- 徐育安（1998），刑法上類推禁止之生與死，台北：自版。
- （2009），費爾巴哈之故意理論及其影響——以德國刑法為核心，
政大法學評論，109期，頁1-57。
 - （2010），間接故意理論之發展——兼論不確定故意、未必故意與
附條件故意，東吳法律學報，21卷3期，頁71-108。
- 許玉秀（1997），前行為保證人類型的生存權？——與結果加重犯
的比較，主觀與客觀之間，頁379-441，台北：自版。
- （1997），客觀的故意概念？——評德國的間接故意理論，主觀與
客觀之間，頁45-159，台北：自版。
 - （1997），區分故意與過失——論認識說，主觀與客觀之間，頁
161-177，台北：自版。
 - （1997），刑法註釋書研究第12至14條（故意犯與過失犯），行政
院國家科學委員會專題研究計劃成果報告，計劃編號：NSC-
84-2414-H-004-004-013-4。
- 許迺曼著，林立譯（2006），由語言學到類型學的故意概念，許玉
秀、陳志輝主編，不移不惑獻身法與正義——許迺曼教授刑事
法論文選輯——賀許迺曼教授六秩壽辰，頁459-501，台北：
新學林。

許迺曼著，許玉秀、鄭昆山譯（1994），刑法上故意與罪責之客觀化，政大法學評論，50期，頁39-68。

許澤天（2007），論侵占罪——德國法的啟發，法令月刊，58卷5期，頁55-65。

黃惠婷（2008），故意與構成要件錯誤，月旦法學教室，72期，頁73-86。

黃榮堅（1998），刑法問題與利益思考，台北：元照。

-（1998），刑法解題——關於故意及過失，刑法問題與利益思考，13-56，台北：元照。

-（2000），故意的定義與定位，刑罰的極限，345-399，台北：元照。

-（2006），基礎刑法學（上），台北：元照。

翟宗泉（1969），犯罪故意之證明方法，法令月刊，20卷9期，頁6-9。

趙彥清（1999），結果加重犯的歸責基礎，政治大學法律學研究所碩士論文。

蔡蕙芳（2005），故意犯罪（一）——直接故意與間接故意，台灣本土法學雜誌，72期，頁166-174。

2. 外文部分

Abegg, Julius F. H. (1836), *Lehbuch der Strafrechts-Wissenschaft*, Neustadt a. d. Orla: Johann Karl Gottfried Wagner.

Altvater, Gerhard (2002), *Rechtsprechung des BGH zu den Tötungsdelikten*, NSTZ, S. 20-27.

Bauer, Anton (1840), *Abhandlungen aus dem Strafrechte und dem Strafprocesse I*, Leipzig: Dieterich.

Bockelmann, Paul (1968), *Bemerkung über das Verhältnis des Strafrechts zur Moral und zur Psychologie*, in: *Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch*, S. 252-259, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Burkhardt, Björn (1987), Der Wille als konstruktives Prinzip der Strafrechtsdogmatik, in: Heinz Heckhausen/Peter M. Gollwitzer/Franz E. Weinert (Hrsg.), *Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften*, S. 319-339, Berlin: Springer.
- Carpzov, Benedict (2000), *Practicae novae imperialis saxonicae rerum criminalium pars I*, übersetzt von Oehler, Goldbach: Keip.
- Engisch, Karl (1963), *Logische Studien zur Gesetzesanwendung*, 3. Aufl., Heidelberg: C. Winter.
- Engelhardt, Hanns (2008), in: *Karlsruher Kommentar zur StPO*, 6. Aufl., München: C.H. Beck.
- Fahl, Christian (1997), Anmerkung zum Urteil des LG Rostock, Urteil vom 16.09.1996 - I KLS 19/96, *NStZ*, 391-392.
- Feuerbach, Paul Johann Anselm (1804), Betrachtungen über dolus und culpa überhaupt und den dolus indirectus insbesondere, in: Ludwig Harscher v. Almendingen/Paul Johann Anselm Feuerbach/Karl Grolman (Hrsg.), *Bibliothek für die peinliche Rechtswissenschaft und Gesetzeskunde*, Bd. 2., S. 193-243, Chemnitz: Chemnitzer.
- (1826), *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, 9. Aufl., Gießen: G.F. Heyes.
- (1847), *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, in: Carl Joseph Anton Mittermaier (Hrsg.), 14. Aufl., Nachdruck 1986, Gießen: G.F. Heyes.
- Frank, Reinhard (1907), Über den Aufbau des Schuldbegriffs, in: *Festschrift für die Juristische Fakultät in Gießen zum Universitätsjubiläum*, S. 521-546, Gießen: G.F. Heyes.
- Frisch, Wolfgang (1983), *Vorsatz und Risiko. Grundfragen des tatbestandsmäßigen Verhaltens und des Vorsatzes. Zugleich ein Beitrag zur Behandlung außertatbestandlicher Möglichkeitsvorteilungen*, München: Heymann.

- (1990), Gegenwartsprobleme des Vorsatzbegriffs und der Vorsatzfeststellung am Beispiel der AIDS-Diskussion, in: Gedächtnisschrift für Karlheinz Meyer, S. 532-566, Berlin: Walter de Gruyter.
- (1990), Riskanter Geschlechtsverkehr eines HIV-Infizierten als Straftat? - BGH 36, 11, JuS, S. 362-370.
- Geppert, Klaus (2001), Zur Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit, insbesondere bei Tötungsdelikten, Jura, S. 55-59.
- Grünhut, Max (1922), Anselm von Feuerbach und das Problem der strafrechtlichen Zurechnung, Nachdruck 1978, Amsterdam: Scientia.
- Hassemer, Winfried (1989), Kennzeichen des Vorsatzes, in: Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, S. 294-309, München: Heymann.
- (1990), Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2. Aufl., München: C.H. Beck.
- Heffter, Augst W. (1854), Lehrbuch des gemeinen deutschen Strfrechts, 5. Aufl., Stockstadt am Main: Kiep.
- Hemmen, Heinrich (1909), Über den Begriff, die Arten und den Beweis des Dolus, Stockstadt am Main: Keip.
- Hillenkamp, Thomas (1989), Dolus eventualis und Vermeidewille, in: Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, S. 351-369, Köln/Berlin/Bonn/München: Heymanns.
- Hruschka, Joachim (1985), Über Schwierigkeit mit dem Beweis des Vorsatzes, in: Festschrift für Theodor Kleinknecht zum 75. Geburtstag, S. 191-202, München: C.H. Beck.
- Jakobs, Günther (1991), Strafrecht. Allgemeiner Teil, Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, 2. Aufl., Berlin: W. de Gruyter.
- Kaufmann, Armin (1958), Der dolus eventualis im Deliktsaufbau, ZStW

70, 64-86.

Kelsen, Hans (1911), Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, Tübingen: J.C.B. Mohr.

Kindhäuser, Urs (1984), Vorsatz als Zurechnungskriterium, ZStW 96, 1-35.

- (2010), Strafgesetzbuch. Lehr- und Praxis Kommentar, 4. Aufl., Baden-Baden: Nomos.

Koriath, Heinz (2010), Über den Vorsatz und wie man ihn beweisen könnte, in: Heinz Koriath u.a. (Hrsg.), Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie und die Reform der Juristenausbildung, S. 103-144, Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.

Krauß, Detlef (1978), Der psychologische Gehalt subjektiver Elemente im Strafrecht, in: Festschrift für Hans-Jürgen Bruns zum 70. Geburtstag, S. 11-30, München: Heymann.

Kühl, Kristian (2005), Strafrecht Allgemeiner Teil, 5. Aufl., München: Vahlen.

Löffler, Alexander (1895), Die Schuldformen des Strafrechts in Vergleichend-Historischer und Dogmatischer Darstellung, Bd. I., Leipzig: Hirschfeld.

Meyer-Goßner, Lutz (1986), Typische materiell-rechtliche Fehler in Strafurteilen aus revisionsrechtlicher Sicht, NSTZ, S. 49-51.

- (2008), StPO, 51. Aufl., München: C.H. Beck.

Perron, Walter (1998), Vorüberlegungen zu einer rechtsvergleichenden Untersuchung der Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit, in: Festschrift für Haruo Nishihara, S. 145-156, Baden-Baden: Nomos.

Philipps, Lothar (2001), An der Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit — Ein Modell multikriterieller computergestützter Entscheidungen, in: Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag, 2001, S. 365-378, Berlin: W. de Gruyter.

- Platzgummer, Winfried (1964), Die Bewußtseinsform des Vorsatzes: eine strafrechtsdogmatische Untersuchung auf psychologischer Grundlage, Wien: Springer.
- Puppe, Ingeborg (1991), Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis, ZStW 103, S. 1-42.
- (1992), Vorsatz und Zurechnung, Heidelberg: Decker & Müller.
 - (2002), Strafrecht. Allgemeiner Teil 1, Baden-Baden Nomos.
 - (2005), in: NK, 2. Aufl., § 15, Baden-Baden: Nomos.
 - (2006), Begriffskonzeptionen des dolus eventualis, GA, S. 65-79.
- Roxin, Claus (1964), Zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit – BGHSt 7, 363, JuS, S. 53-61.
- (2004), Zur Normativierung des dolus eventualis und zur Lehre von der Vorsatzgefahr, in: Festschrift für Hans-Joachim Rudolph zum 70. Geburtstag, S. 243-257, München: Wolters-Kluwer.
 - (2006), Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Bd. 1., Grundlagen der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Aufl., München: C.H. Beck.
- Ruß, Wolfgang (1994), in: LK, 11. Aufl., Berlin: Walter de Gruyter.
- Schaffstein, Friedrich (1930), Die allgemeinen Lehren vom Verbrechen in ihrer Entwicklung durch die Wissenschaft des gemeinen Strafrechts, Nachdruck 1986, Berlin: Springer.
- Schlehofer, Horst (1996), Vorsatz und Tatabweichung, Zur Auslegung der §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 22 StGB, Köln: Heymann.
- Schmidhäuser, Eberhard (1985), Strafrechtlicher Vorsatzbegriff und Alltagssprachgebrauch, in: Festschrift für Dietrich Oehler zum 70. Geburtstag, S. 135-161, Köln: Heymann.
- Schneider, Hartmut (2003), in: MK, § 211, München: C.H. Beck.
- Schroth, Ulrich (2008), Der bedingte Tötungsvorsatz im Spiegel der Rechtsprechung, in: Festschrift für Gunter Widmaier zum 70. Geburtstag, S. 779-799, Köln: C. Heymanns.

- Steinberg, Georg/Fabian Stam (2011), Der Tötungsvorsatz in der Revision des BGH, NStZ, S. 177-186.
- Trück, Thomas (2005), Die Problematik der Rechtsprechung des BGH zum bedingten Tötungsvorsatz, NStZ S. 233-240.
- v. Hippel, Robert (1908), Vorsatz, Fahrlässigkeit, Irrtum, in: Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Allgemeiner Teil, Bd. 3., 454-599, Berlin: Otto Liebmann.
- Verrel, Torsten (2004), (Noch kein) Ende der Hemmschwellentheorie?, NStZ, S. 309-312.
- Volk, Klaus (2000), Begriff und Beweis subjektiver Merkmale, in: 50 Jahre Bundesgerichtshof Festgabe aus der Wissenschaft, S. 739-753, München: C.H. Beck.
- Wenig (1818), Über die Vermutung des bösen Vorsatzes nach dem römischen Rechte, in: Neues Archiv des Kriminalrechts, Bd. 2., S. 194-237.